

제26장

증 인

-
- 제1절 총 설 54
 - 제2절 증인의 신청 및 채부의 결정 55
 - 제3절 증인조사의 방식 61
 - 제4절 증인에 대한 출석요구 및 출석확보 74
 - 제5절 증인신문의 방법 82
 - 제6절 증인신문조서의 작성 112
 - 제7절 증인에 대한 과태료재판 120
 - 제8절 증인에 대한 감치재판 130

제1절 총 설

1. 의 의

증인이란 과거에 경험하여 알게 된 사실을 법원에 보고(진술)할 것을 명령 받은 사람으로서 당사자 및 법정대리인(대표자 포함) 이외의 제3자를 말하고, 증인의 증언으로부터 증거자료를 얻는 증거조사를 증인신문이라고 한다.

당사자·법정대리인 및 당사자인 법인 등의 대표자 이외의 자는 모두 증인 능력을 갖는다. 소송무능력자나 당사자의 친족이라도 상관없다.

제3자의 소송당당에 있어서 이익귀속주체(예컨대 파산관재인을 당사자로 하는 파산재단에 관한 소송에서 채무자, 선정당사자를 선정하고 소송에서 탈퇴한 선정자, 채권자대위권에 의해 채권자가 제기한 소송에서 채무자 등), 소송대리인, 보조참가인, 소송고지에 있어서 피고지자, 법인 등이 당사자인 경우에 대표자 아닌 구성원도 증인이 될 수 있다. 공동소송인도 자기의 소송관계와 무관한 사항에 관하여는 증인이 될 수 있다. 다만 공동의 이해관계 있는 사항에 대해서는 당사자신문을 요할 것이다. 그러나 제1심의 공동소송인이었다가 항소심에서 공동소송인이 아닌 경우는 아무 제한 없이 증인이 될 수 있다.

2. 증인의무

우리나라의 재판권에 속하는 사람은 원칙적으로 모두 증인의무가 있는데 그 의무의 내용은 출석의무·선서의무·진술의무의 세 가지로서 이는 공법상의 의무이므로 정당한 이유 없이 응하지 아니하면 과태료가 부과되거나 감치되고(민소 311조, 318조) 구인될 수 있다(312조). 증인이 출석요구를 받고 기일에 출석할 수 없을 경우에는 바로 그 사유를 밝혀 신고하여야 하며(민소 규 83조), 이러한 신고를 하지 않으면 불출석에 대한 제재를 받을 때에 불리한 정상으로 고려될 수 있다.

다만 대통령·국회의장·대법원장·헌법재판소장 또는 그 직책에 있었던 사람에 대하여 그 직무상 비밀에 관한 사항에 대한 증인신문을 하려면 법원은 그의 동의를 받아야 한다(민소 304조). 또 국회의원·국무총리나 국무위원·공무원 또는 그 직책에 있었던 사람에 대하여 그 직무상 비밀에 관한 사항에 대한 증인신문을 하려면 각각 국회·국무회의·공무원의 소속 관청 또는 감독 관청의 동의를 받아야 한다(305조, 306조). 이 경우 국회·국무회의·해당 관청은 국가의 중대한 이익을 해치는 경우를 제외하고는 그 동의를 거부하지 못한다(307조).

공무원 또는 공무원이었던 사람이 직무상 비밀에 관한 사항에 대하여 증언하게 된 때에는 증언할 사항이 직무상 비밀에 해당하는 사유를 구체적으로 밝혀 법원에 미리 신고하여야 하고, 이 경우 법원이 필요하다고 인정하는 때에는 그 소속 관청 또는 감독 관청에 대하여 신문할 사항이 직무상 비밀에 해당하는지 여부에 관하여 조회할 수 있다(민소규 78조). 조회결과를 토대로 법원이 신문할 사항이 직무상 비밀에 해당된다고 판단하면 다시 소속 관청 또는 감독 관청에 별도의 동의절차를 거쳐야 할 것이고, 그렇지 않고 신문할 사항이 직무상 비밀이 아니라고 판단하면 조회결과에서 직무상 비밀이라고 하더라도 동의절차를 거칠 필요 없이 증인신문을 실시하면 될 것이다.

제2절 증인의 신청 및 채부의 결정

1. 증인신청의 시기와 방법

가. 시 기

증인신문은 당사자의 주장과 증거를 정리한 뒤 집중적으로 실시하여야 하므로(민소 293조), 당사자는 특별한 사정이 없는 한 필요한 증인을 쟁점정리를 위한 기일 이전에 신청하여야 한다.

나. 서면신청의 원칙

증인을 신청하는 때에는 증인의 이름·주소·연락처·직업, 증인과 당사자의 관계, 증인이 사건에 관여하거나 내용을 알게 된 경위 등을 구체적으로 밝혀야 한다(민소규 75조 2항). 그 방식은 서면으로 함이 원칙이다. 집중증거조사방식에서는 증인이 일괄 신청되고 일괄하여 채부 결정을 하게 되므로, 각 증인별로 증명취지 및 당사자들과의 관계를 미리 명확하게 밝혀야만 증인의 채부 결정 및 증인에 대한 구체적 신문방법을 결정할 수 있기 때문이다. 아울러 증인신청서에는 증인에 대한 출석 여부 확인 및 출석확보를 위하여 주소 외에도 연락 가능한 전화번호 등을 적어야 하고 증인의 출석을 확보하기 위한 협력방안을 밝혀야 한다(75조 2항).

실무상으로는 정형화된 증인신청서[전산양식 A1730]를 만들어 사용하고 있는데, 기일에 말로 신청하던 과거의 관행이 개선되고 양식의 해당란이 충실하게 기재되도록 적극 유도할 필요가 있다.

아울러 신청인은 증인에게 장애인 사법지원(편의제공)이 필요하다면 구두로라도 미리 밝히는 것이 바람직하다. 장애인 사법지원(편의제공) 안내문[전산양식 A5200 등]과 신청서[전산양식 A5230 등]를 활용한다. 대한민국 법원 전자소송포털(<http://ecfs.scourt.go.kr/>) 소송안내마당의 재판지원 메뉴에서 ‘장애인 사법지원’ 부분을 참고할 수 있다.

[전산양식 A1730] 증인신청서

증 인 신 청 서

1. 사건: 20 가단(합, 소)
2. 증인의 표시

성명	김 희 연					
생년월일	1964. 1. 1.					
주 소	서울 ○○구 ○○로 123, 2층					
전화번호	자택	(02) 555 - 777x	사무실	(02) 777 - 999x	휴대 전화	(010) 7123-456x
원·피고 와의 관계	원고 처의 친구(고등학교 동창)					

3. 증인이 이 사건에 관여하거나 그 내용을 알게 된 경위
이 사건 임대차계약을 체결할 당시 원고, 원고의 처와 함께 계약현장에 있었던
4. 신문할 사항의 개요
 - ① 예시) 이 사건 임대차계약 당시의 정황
 - ② 예시) 임대차 계약서를 이중으로 작성한 이유
5. 희망하는 증인신문방식(해당란에 “✓” 표시하고 희망하는 이유를 간략히 기재)
☒ 증인진술서 제출방식 ☐ 증인신문사항 제출방식 ☐ 서면에 의한 증언방식
 이유: 예시) 원고 측과 연락이 쉽게 되고 증인진술서 작성 의사를 밝혔음
6. 증인의 출석을 확보하기 위한 협력방안(해당란에 “✓” 표시)
☐ 기일에 함께 출석하기로 협의함 ☐ 채택 후 출석여부를 확인할 예정임
☐ 별다른 방안을 강구하기 어려움 ☐ 기타 ()
☐ 영상신문을 통한 증언을 원함 (유의 사항 4. 참조)
7. 예상 소요 시간(주신문)
☐ 15분 ☐ 30분 ☐ 기타 (분)
8. 그 밖에 필요한 사항

20○○. ○. ○.

(원/피)고 소송대리인

서명 또는 날인

법원 귀중

◇ 유의 사항 ◇

1. 증인이 이 사건에 관여하거나 그 내용을 알게 된 경위는 구체적이고 자세하게 적어야 합니다.
2. 여러 명의 증인을 신청할 때에는 증인마다 증인신청서를 따로 작성하여야 합니다.
3. 신청한 증인이 채택된 경우에는 법원이 명하는 바에 따라 증인진술서나 증인신문사항을 미리 제출하여야 하고, 지정된 신문기일에 증인이 반드시 출석할 수 있도록 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.
4. 증인이 법정에 직접 출석하기 어렵거나 당사자 등과 대면하여 진술하면 심리적인 부담으로 정신의 평온을 현저하게 잃을 우려가 있는 경우 영상으로 증인신문을 할 수 있습니다(민사소송법 제327조의2). 영상신문을 실시할 것인지 여부는 법원이 당사자의 의견을 들어 직권으로 결정합니다.

다. 일괄신청의 원칙

집중증거조사기일에서는 한 기일에 일괄하여 증인신문을 행하게 되므로, 증인신문은 부득이한 사정이 없는 한 일괄하여 신청하여야 한다(민소규 75조 1항). 여기서 일괄이라는 것은 동일한 기회에 모든 증인을 한 번에 신청하여야 한다는 의미는 아니고, 쟁점정리를 위한 기일이 끝나기 전(가능하면 그 기일이 시작되기 전)까지 당사자가 예정하고 있는 증인 전부에 대하여 신청절차를 마쳐야 한다는 의미이다. 일괄신청을 적극 유도하는 방법의 하나로서, 증인신청이 있는 때에 그 신청서 부분을 곧바로 상대방에게 송달함으로써 상대방으로 하여금 조기에 이에 대한 대응책을 마련하도록 하는 방안이 유용하게 활용될 수 있다.

다만 집중증거조사는 주장 및 쟁점이 정리된 후 한꺼번에 증거조사를 실시함으로써 심리를 충실화한다는 취지이므로, 의료소송·환경소송·소비자소송 등과 같이 사안이 복잡하고 다수의 이해관계인이 등장하거나 증거가 편재되어 있는 사건 등 통상적인 일괄신청의 방식이 적합하지 아니한 경우에는 예외를 허용함이 불가피하다. 여기에 해당하는 예를 구체적으로 들면, ① 증거가 한쪽 당사자에게 집중되어 있어서 특정 증인에 대한 신문이 선행되지 않고는 쌍방의 주장·증명이 곤란하여 증거도출을 위한 증인신문, 이른바 모색적 증인신문을 선행하여야 할 필요가 있는 경우, ② 의료사건에서 환자가 피고 병원에 후송된 직후 응급진료를 담당한 의사, 상속재산인 주식의 무단처분이 다투어지고 있는 사건에서 그 주식의 관리를 담당하던 증권회사 담당직원 등과 같이 그 증인의 증언을 듣지 아니하면 주장·증명의 구성이 곤란하면서도 소송 외에서는 협력을 구할 수 없는 증인을 신청하는 경우, ③ 손해배상책임의 발생 여부와 손해의 범위와 같이 논리적으로 선후관계가 있고 각 단계별로 쟁점이 복잡한 사건에서 논리적으로 선행하는 쟁점에 관하여 쟁점정리를 하고 그에 대한 집중증거조사를 하는 방식으로 심리를 단계화하는 것이 타당한 경우, ④ 그 밖에 통상적인 사건에서도 증언의 필요성

이 높은 중립적 증인에 대하여 시간을 맞추기가 어렵거나 출석확보가 곤란하여 그 증인에 대하여 따로 증인신문기일을 지정하는 것이 바람직한 경우 등이 있다.

라. 증인재신문

이미 신문한 증인에 대한 재신문은 해당 증인의 종전 증언을 탄핵하기 위한 경우와 종전 증언에 신빙성을 부여하기 위한 경우로 구분할 수 있는데, 법원은 이러한 신청의도와 재신문이 필요한 개별적 사유, 중립적 증인의 반복적 출석에 따른 불편, 종전 증언 이후의 사정변경(새로운 증거의 제출, 쟁점의 추가 또는 변경 등) 등 증거조사의 필요성과 절차운영의 적정성을 고려하여 그 채부를 결정한다.

가령 상대방 측 당사자가 책임질 수 없는 사유로 말미암아 종전 증인신문 절차에 출석하지 못하여 반대신문의 기회를 부여할 필요가 있는 경우, 증인의 당초 증언에 모순점, 불명확성, 다의성이 있고 해당 부분의 증언이 쟁점 판단에 필요한 경우 등은 재신문의 필요성이 높다고 볼 수 있다. 반면, 막연히 종전 증인신문절차에서 증인에 대한 신문이 충분하지 못하였다고 하거나, 종전 증언에 관한 구체적인 탄핵자료를 제시하지 않은 채 종전 증언의 모순점 등을 재신문을 통하여 밝히겠다고만 하면서 증인재신문을 신청하는 경우에는 재신문의 필요성이 인정되기 어렵다.

민사소송법은 직접주의의 요청에 따라 종전 증언에 대한 동일한 증거평가를 유지하기 위하여, 단독사건의 판사가 바뀔 경우나 합의부 법관의 반수 이상이 바뀔 경우에 종전에 신문한 증인에 대하여 당사자가 다시 신문신청을 한 때에는 법원이 그 신문을 하여야 한다고 규정하고 있다(민소 204조 3항). 다만 위와 같은 경우에 해당하더라도, 법원이 소송상태에 비추어 재신문이 필요하지 아니하다고 인정하는 경우(예를 들면, 종전에 증인을 신문할 당시에는 당사자 사이에 다툼이 있었으나 현재는 당사자 사이에 다툼이 없어서 증명이 필요

없게 된 경우, 다른 증거들에 의하여 심증이 이미 형성되어 새로 심증을 형성할 가능성이 없는 경우, 소송의 완결을 지연하게 할 목적에서 재신문을 신청하는 것으로 인정되는 경우 등)에는 민사소송법 290조에 따라 재신문을 하지 아니할 수 있다(대법원 1992. 7. 14. 선고 92누2424 판결).

2. 채부 결정 및 조사방식의 고지

법원은 일괄신청된 증인에 대한 채부를 쟁점정리를 위한 기일에 일괄하여 결정·고지한다. 쟁점정리를 위한 기일에 일괄하여 채부 결정을 하는 이유는 쟁점정리 과정에서 당사자 사이의 다툼이 정리되어 증인신문이 필요 없게 될 수도 있고, 관련 증인의 일괄 집중신문을 위해서는 법원과 당사자가 기일 진행 및 증인의 출석확보방안에 관하여 협의를 할 필요가 있기 때문이다.

법원은 증인의 채부 결정과 함께 개별 증인별로 증명취지 및 당사자와의 관계 등을 고려하여 ① 증인진술서 제출 방식, ② 증인신문사항 제출 방식, ③ 서면에 의한 증언 방식 중 하나의 증인조사방식을 선택하여 쌍방에게 고지한다. 특히 증인진술서 방식을 채택할 경우에는 당사자에게 그 취지와 요령을 알아듣기 쉽게 설명함으로써 효과적으로 증인신문을 준비하도록 주의 를 환기시키는 것이 중요하다. 참여사무관은 증인별로 그 조사방식에 따라 서면증언의 경우에는 증인등목록의 ‘증거조사’란에 “서면증언(20〇〇. 〇. 〇. 까지)”으로, 증인진술서 또는 증인신문에 의한 증언의 경우에는 ‘비고’란에 “진술서(20〇〇. 〇. 〇.까지)”, “신문사항(20〇〇. 〇. 〇.까지)”과 같은 방법으로 그 제출기한을 기재하여야 한다(민사증거목록예규 19조 3항, 20조 9호). 또한 증인신문의 구체적 방법(신문순서, 대질신문 및 재정신문 활용 여부, 개략적인 신문시간)에 관하여 협의가 이루어진 경우에는 그 취지를 조서에 기재하도록 하며, 증인의 출석확보 방안 등도 확인해야 한다. 주신문과 반대신문의 각 예상소요시간을 물어서 확인해두는 것과, 나아가 이를 전산상 입력하여 재판부 일정에 표시되게 해두는 것이 바람직한 조치이다.

재판장은 당사자로 하여금 해당 증인에 의하여 증명할 사실을 개별적으로 설명하게 함으로써 증인신문이 쟁점에 집중하여 이루어지도록 한다(사건관리 예규 14. 나.).

기일에 말로 증인을 신청하는 방식 또는 인적사항이 불특정된 증인이나 예비적·택일적으로 증인을 신청하는 방식은 원칙적으로 허용하지 아니한다. 예외적으로 허용할 만한 경우라면 증인을 채택하고 조사방식을 고지하되 정형화된 양식의 증인신청서를 즉시 제출할 것을 명하는 방법은 있다. 이보다 원칙적인 방법은, 기일에는 일단 증인의 채부를 보류하고 일정한 기간 내에 서면에 의한 증인신청서(또는 이와 함께 증인진술서 내지 증인신문사항까지)를 제출하도록 한 다음, 기일 외에서 증명취지 등을 확인하여 채부 및 증인조사 방식을 결정하는 방법이다. 이러한 원칙적 방법에 따라 기일 외에서 채택 결정을 한 경우 증인등목록의 ‘기일 및 장수’란에는 “1차” 식으로 증거를 신청한 기일을, ‘증거결정’란에 “기일 외”, “채”로 각각 기재한다. 증인신청서를 따로 제출하지 아니하고 준비서면의 내용 중에 신청할 증인과 증명취지, 당사자와의 관계 등을 기재한 경우에도 위와 같이 처리함이 적절하다.

제3절 증인조사의 방식

1. 증인진술서 제출 방식

가. 취 지

종래 교호신문방식에 따른 증인신문의 상당수가 형식적·비효율적으로 운영된 점을 개선하기 위하여 민사소송규칙 79조는 증인진술서 제도를 도입하였다. 즉 효율적인 증인신문을 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 법원은 증인진술서를 제출하게 하여 상대방에게 미리 송달하고, 법정에서는 쟁점사항에 한정하여 주신문을 하고 나머지 증명할 사실에 관하여는 위 증인진술

서가 사실대로 작성되었다는 취지의 증언을 함으로써, 실질적인 증인신문(반대신문)을 가능하게 하고 나아가 서면방식에 의하여 증거를 개시하자는 데 그 취지가 있다.

여기서의 증인진술서는 서증의 일종이기는 하나, 증인을 신청한 당사자로 하여금 제출케 하는 방식을 가리킨다는 점에서 어느 당사자권 제출할 수 있는 통상적인 진술서와 개념상 구별된다. 이 경우, 진술서·사실확인서 등을 공증인의 사서증서 인증을 받아서 제출하는 인증진술서가 많이 활용되고 있다.

나. 활용 범위

법원은 효율적인 증인신문을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 증인을 신청한 당사자에게 증인신문기일 이전에 미리 증인진술서를 제출하게 할 수 있다(민소규 79조 1항). 그 활용 범위에 관하여 특별한 제한은 없으나, 특히 증인을 신청한 당사자의 지배영역 내에 있다고 판단되는 증인(가족, 친지, 회사의 직원 등)에 대해서는 증인진술서의 제출을 명하는 것을 활용할 수 있다.

반면, 증인이 이른바 적대적 증인인 경우, 글을 쓸 수 없는 경우, 증언내용을 미리 밝히는 것이 사건의 공정한 해결을 위하여 바람직하지 아니하다고 인정되는 경우 등에는 증인진술서를 제출하게 하지 않는 것이 적절하다.

다. 증인진술서의 작성 및 제출

(1) 증인진술서의 제출

증인진술서의 제출명령은 원칙적으로 기일에 채부의 결정을 고지하면서 함께 이루어진다. 명령의 상대방은 증인이 아니라 증인을 신청한 당사자이다(민소규 79조 1항). 동일한 증인을 양쪽 당사자가 동시에 신청한 경우에 증인과 양쪽 당사자 사이의 관계 등을 고려하여 주된 신청인 측에 명령을 부과하되, 만일 중립적 증인으로서 어느 일방에게만 증인진술서의 제출을 명하는 것이 알맞지 아니한 때에는 증인신문사항으로 대체한다.

증인진술서의 제출을 명하는 때에는 상대방에 대한 송달기간, 반대신문을 위한 준비기간 등을 고려하여 그 제출기한을 정하여야 한다(민소규 79조 3항 참조). 실무상 증인신문기일 1주 내지 10일 전까지를 제출기한으로 정하는 예가 많다. 양쪽 당사자가 각자 다른 증인을 신청하고 그에 대하여 증인진술서의 제출을 명하는 때에는 특별한 사정이 없는 한 쌍방의 제출기한을 동일하게 설정하는 등 절차상의 공평에 유의할 필요가 있다.

증인진술서는 원본과 함께 상대방의 수에 2(다만 합의부에서는 상대방의 수에 3)를 더한 통수의 사본을 제출하도록 하여(민소규 79조 3항), 원본은 기록에 편철하고, 사본은 상대방에 대한 송달과 재판부 및 참여사무관이 증인신문 및 조서작성과정에서 참고자료로 활용한다. 증인진술서는 전자소송시스템을 이용하여 전자적으로 제출할 수 있고, 재판장등이 명하거나 상대방이 신청한 때에는 증인진술서 원본을 제출하여야 한다(민전규 35조).

증인진술서가 제출되면 참여사무관은 증인진술서 사본 1통을 바로 상대방에게 송달하여 반대신문을 준비할 수 있도록 하여야 한다(민소규 79조 4항). 증인에게는 따로 송달할 필요가 없다.

증인진술서가 제출된 사건에 관하여는 원칙적으로 증인신문사항의 제출을 면제한다(민소규 80조 1항 단서). 다만 제출된 증인진술서의 내용이 지나치게 장황하거나 구체성이 없는 경우, 법률적 견해 위주로 작성되어 있는 경우 등 부적절한 진술서가 제출된 때에는 서증으로 채택하지 아니하고 제출자에게 반환하며(민소 355조 4항), 해당 증인에 대한 신문은 그대로 실시할 필요가 있는 때에는 별도로 증인신문사항을 제출하도록 명함이 타당하다.

지정된 기한 안에 증인진술서가 제출되지 아니한 때에는 참여사무관은 당사자에게 그 제출을 촉구한다. 만일 정당한 사유 없이 이에 응하지 아니하는 때에는 재판부는 그 기일에서의 증인신문을 허용하지 아니하거나 그 증인에 대한 필요성을 재고하여 증거채택결정을 취소하는 등 적절하게 대처하여야 한다.

(2) 증인진술서의 형식

증인진술서에는 증언할 내용을 그 시간 순서에 따라 적고, 증인이 서명날 인하여야 한다(민소규 79조 2항).

증인진술서의 형식적 기재사항으로는 그 첫머리에 사건번호·사건명, 증인의 이름·주소 및 전화번호(특히 일과 중에 연락 가능한 전화번호 또는 휴대전화 번호) 등을 기재하며, 말미에는 작성한 날짜를 적고 작성자(증인)가 서명날인을 하여야 한다.

증인진술서의 본문에는 증언할 내용을 사건 진행의 시간적 경과에 따라 기재하되, 자신이 직접 경험하지 아니한 사실을 기재하는 때에는 그 사실을 알게 된 근거를 구체적으로 밝혀야 하며, 증인의 의견이나 법률적 견해를 적어서는 안 된다.

증인진술서의 제출을 명하는 때에는 진실 서약 및 법정출석 확약 문언과 작성일자를 기재하도록 하는 내용을 담은 증인진술서 작성 안내서[전산양식 A1731]를 교부한다.

[전산양식 A1731] 증인진술서(작성 안내)

증인진술서 작성 안내

증인진술서는 증인으로 채택된 사람이 증언할 내용을 적어 법원에 미리 제출하는 서면을 말합니다.

증인진술서는 다음과 같은 방식으로 작성하여, 상대방의 수에 2(다만 합의부의 경우에는 상대방의 수에 3)를 더한 만큼의 사본을 함께 제출하여야 합니다.

◇ 작성 방법 ◇

1. 증인진술서에는 먼저 증언할 사건의 표시(법원, 사건번호, 사건명)와 증인의 인적사항(이름, 생년월일, 주소, 전화번호) 및 당사자와의 관계를 적은 다음, 증인이 증언할 내용을 사건이 진행된 시간 순서에 따라 간결하게 적어야 합니다.
2. 특히 증언할 내용이 증인 자신이 직접 경험한 것인지 여부를 기재하여야 하고, 만일 자신이 직접 경험하지 않은 사실을 적었을 때에는 그 사실을 알게 된 경위(예컨대, “언제 어디서 ○○○로부터 들었다.”)를 분명하게 밝혀야 합니다.
3. 증인진술서에는 개인적인 의견이나 법률적 견해를 적어서는 안 됩니다.
4. 증인진술서의 말미에는 “이상의 내용은 모두 진실임을 서약하며, 이 진술서에 적은 사항의 신문을 위하여 법원이 출석요구를 하는 때에는 법정에 출석하여 증언할 것을 약속합니다.”라는 문구와 증인진술서를 작성한 날짜를 적고, 작성한 사람이 서명·날인하여야 합니다.

※ 구체적 작성례는 뒷면 참조

증 인 진 술 서

사 건 20 가

원 고 김 ○ ○

피 고 이 ○ ○

진술인(증인)의 인적사항

이 름: 박 ○ ○

생년월일: 1970. 11. 25.

주 소: 서울 00구 00로 000

전화번호: 02-000-0000(휴대폰 010-0000-0000)

1. 진술인은 2014년경 친한 친구로부터 피고를 소개받았는데, 진술인이 장사를 하는 관례로 급전이 필요할 때가 많아 그 무렵부터 여러 차례에 걸쳐 피고로부터 돈을 빌리게 되었고, 개인적으로도 친하게 지내 왔습니다.
2. 그러던 중 피고가 2025년 1월경부터 자신의 아들 이름으로 소유하고 있는 서울 관악구 00로 000 서울아파트 101동 201호를 팔려고 한다면서 진술인에게도 혹시 주위에 살 사람이 있으면 소개하여 달라고 한 사실이 있습니다.
3. 진술인은 2025년 4월경 피고로부터 빌린 차용금의 이자를 갚으러 피고의 집에 갔다가 그곳에 와 있던 원고를 처음으로 보게 되었습니다. 그날 원고와 피고는 그 자리에서 위 아파트의 매매관계에 관하여 이야기를 나누었던 것으로 기억하는데, 그날 계약서를 작성하였는지는 모릅니다.
4. 진술인은 그 며칠 뒤쯤 피고로부터 위 아파트를 원고에게 팔았다고 하는 이야기를 전화로 듣고 잘되었다고 생각하고 있었습니다. 그런데 그 후 보름쯤인가 지난 다음에 피고를 길거리에서 우연히 만났는데, 피고가 하는 말이 원고가 위 아파트를 살 수 없게 되었으니 제발 계약금을 되돌려 달라고 사정 사정을 하여 할 수 없이 그 절반만 돌려주고, 서로 없던 일로 하기로 하였다는 이야기를 들은 사실이 있습니다. 그 무렵이나 그 후에 원고를 만난 일은 없습니다.
5. 이상의 내용은 모두 진실임을 서약하며, 이 진술서에 적은 사항의 신문을 위하여 법원이 출석요구를 할 때에는 법정에 출석하여 증언할 것을 약속합니다.

20○○. ○. ○.

진술인 박○○ (서명 또는 날인)

라. 증인진술서를 이용한 증인신문의 방법

증인진술서가 제출된 경우에는 집중증거조사기일에 이를 신청한 당사자가 제출한 서증으로 채택하고, 법정에서는 경위사실·정황사실 및 주변사실은 증인진술서 기재로 대체하고 주신문은 핵심 쟁점사항(통상적인 사건을 기준으로 4~5항 정도)에 한정하며, 상대방의 반대신문권을 충분히 보장하는 방향으로

로 운영하되, 주신문절차에서 증인진술서의 진정성립만 확인하고 주신문을 전면 생략하는 방식은 타당하지 아니하다[사건관리예규 14. 다. (1)].

한편, 증인은 재판장의 허가가 없는 한 서류에 의하여 진술하지 못하므로 (민소 331조), 증인진술서의 진정성립을 인정하기 위하여 증인에게 진술서를 제시하는 경우를 제외하고는 증인이 증인진술서나 그 사본을 보면서 답변하도록 허용하는 것은 적절하지 아니하다.

증인진술서를 제출한 증인이 불출석하는 경우에, 그 증인진술서를 서증으로 채택하면 상대방의 반대신문권이 사실상 침해되는 결과가 되므로 원칙적으로 서증으로도 채택하지 않아야 한다. 다만 증인이 사망·질병 등 부득이한 사유로 불출석한 경우, 상대방이 특별한 이의를 제기하지 않는 경우도 있을 수 있으므로, 증인이 증언할 내용, 불출석 사유, 상대방의 의견 등을 고려하여 활용 여부를 정하는 것이 적절하다.

2. 증인신문사항 제출 방식

가. 범 위

증인진술서의 제출을 명함이 적당하지 아니한 사건, 예를 들면, ① 그 증인이 이른바 적대적 증인이거나 신청인의 지배영역 내에 있지 아니한 중립적 증인인 경우, ② 증인이 글을 읽거나 쓸 수 없는 경우, ③ 사건이나 증인의 특성상 그 증언내용을 미리 밝히는 것이 사건의 공정한 해결을 위하여 바람직하지 아니한 경우 등에는 증인진술서 대신 증인신문사항을 제출하도록 한다.

나. 증인신문사항의 작성 및 제출

증인신문을 신청한 당사자는 증인신문신청이 채택된 경우에 법원이 증인진술서를 제출하게 하면서 증인신문사항을 제출할 필요가 없다고 인정하는 경우를 제외하고는, 법원이 정한 기한까지 상대방의 수에 3(다만 합의부에서

는 상대방의 수에 4)을 더한 통수의 증인신문사항을 적은 서면을 제출하여야 한다(민소규 80조 1항 — 진술서와 달리 원본 제출이 없으므로 1통이 추가된다). 증인신문기일 전에 상대방에게 사본 1통씩 송달되며(2항), 사본 중 1통은 출석요구서와 함께 증인에게 송달되고, 나머지는 증인신문 및 조서작성과정에서 재판부와 참여사무관이 참고자료로 활용한다. 통역인(수어통역인 포함)을 위하여 사본을 더 준비해야 하는 경우가 있을 수 있다.

증인신문사항을 제출할 기한은 상대방에 대한 송달 및 반대신문 준비를 위하여 충분하다고 인정되는 기간을 가늠해서 정하며, 제출된 증인신문사항은 상대방에게 송달하되, 불가피한 사정이 없는 한 쌍방의 증인신문사항을 동시에 송달하는 방법 등으로 절차상 공평을 기할 필요가 있다. 상대방의 실질적인 반대신문권을 보장하기 위하여, 증인신문 개시 전에 교부하면 되는 것이 아니라 증인신문기일 전에 반드시 송달하여야 한다(민소규 80조 2항). 다만, 상대방이 증인신문 당시 증인신문사항을 기재한 서면을 미리 받지 못하였다고 하더라도 지체 없이 이의하지 아니하면 이의권의 포기·상실로 볼 것이다(구 민소규 61조 2항에 관한 대법원 2001. 10. 12. 선고 2001다35372 판결 참조).

증인신문사항을 적은 서면은 증인이 채택된 이후에 법원이 정한 기한 내에 제출하는 것이 보통이나, 법원이 신청한 증인의 채부를 결정하기 위하여 필요한 때에는 증인신청단계에서 제출하게 할 수도 있다.

제출된 증인신문사항에 유도신문에 해당하거나 불필요한 내용이 포함되어 있는 경우 등에는 재판장은 증인신문사항 수정명령을 활용하여야 한다(민소규 80조 3항). 증인신문사항까지 미리 제출하게 하고 이를 제출받은 후에 증인 채부 결정을 할 수 있으므로, 수정명령에 따른 수정이 올바르게 이뤄진 것을 확인한 후에 채택 결정하는 방법도 있다. 증인신문사항 수정명령의 기재례는 [전산양식 A1732], [전산양식 A1733]으로 마련되어 있다.

상대방에 대한 송달방법으로는 전자송달을 흔히 이용하지만, 우편송달이

면 기일통지서·준비서면 등 다른 서류를 송달할 기회가 있을 때 이를 동봉하여 송달하거나, 팩시밀리 등을 이용하여 송부하는 것이 좋다. 양쪽 당사자 모두 변호사가 대리인으로 선임되어 있는 경우에는, 증인신문사항의 제출을 명할 때 신청인 측 변호사에게 증인신문사항의 전자파일을 전자우편으로 상대방 변호사에게 보내게 하고 법원에 제출할 증인신문사항 중 상대방용 1통을 줄여주는 방법으로 유도할 수 있다(민소규 47조 참조).

증인신문의 채택결정 후 제출한 증인신문사항이 증인신문 신청 시에 밝힌 증명취지와 다른 경우에는 증인채택결정을 취소할 수 있다. 증인신문의 시작 직전에, 변경된 증인신문사항이 제출되거나 추가신문사항이 제출된 경우에는, 종전 신문사항의 범위를 크게 벗어나지 아니하면 신문을 허용할 것이지만, 그렇지 아니한 때에는 증인과 상대방 당사자의 의견을 물어 신문 여부를 결정하여야 한다.

3. 서면에 의한 증언방식

가. 서 설

법원은 증인과 증명할 사항의 내용 등을 고려하여 상당하다고 인정하는 때에는 출석·증언을 갈음하여 증언할 사항을 적은 서면을 제출하게 할 수 있다(민소 310조 1항).

서면에 의한 증언방식으로 과거에는 공정증서에 의한 증언제도가 인정되었는데, 이 제도는 증인 채택 단계에서 상대방이 이의하지 않는 경우에 한하여 실시할 수 있고, 그 증언절차도 공정증서 정본을 제출하게 하는 등 상당히 복잡하여 거의 이용되지 아니하였다.

이에 민사소송법 310조는 ① 상대방의 이의 유무에 관계없이 법원이 상당하다고 인정하는 경우에는 서면증언으로 출석·증언을 갈음할 수 있게 하고, ② 그 서면을 공정증서로 한정하지 아니하며, ③ 법원이 신문사항 또는 신문사항의 요지만에 의하여 증인이 증언할 사항을 바로 적어서 낼 수 있도

록 함으로써 절차상의 효율을 도모하고 있다.

법원은 상대방의 이의가 있거나 필요하다고 인정하는 때에는 증인으로 하여금 출석·증언하게 할 수 있다. 법원은 신문사항의 내용, 증인의 신뢰성 등을 고려하여 서면증언이 적절한지를 재량으로 결정한다. 당사자는 증인 신청과 동시에 법원에 서면증언을 희망한다는 의견을 개진할 수 있으나, 이는 직권발동을 촉구하는 의미를 지닐 뿐이다.

서면증언과 증인진술서는 증거의 성질이 전자는 증언에 해당하는 반면 후자는 서증의 일종이라는 점, 전자는 증인에게, 후자는 증인을 신청한 당사자에게 그 제출을 명한다는 점, 전자는 원칙적으로 서면의 제출과 법정에서의 현출로 그 증거조사절차가 마쳐지는 데 비하여 후자는 법정 출석과 증인신문이 뒤따른다는 점에서 차이가 있다.

나. 활용 범위

공시송달사건, 피고가 형식적인 답변서만 제출하고 출석하지 아니하는 사건 등에서는 서면에 의한 증언을 활용한다(사건관리예규 14. 가.). 물론 그러한 사건에서도 변론 전체의 취지에 의하여 서증의 진정성립이 인정되고 그 서증만으로 요건사실의 인정이 가능한 경우와 같이 그 필요성이 없는 때에는 서면에 의한 증언을 생략할 수 있다.

그 밖에도 서면에 의한 증언 방식을 활용하는 것이 알맞은 구체적 사례로는, ① 사건의 경위나 정황 등 당사자 사이의 실질적 다툼의 대상이 아닌 사실을 진술하는 경우, ② 객관적으로 기재된 문서를 전문적 지식에 의하여 설명 또는 정리하는 경우(회계·경리관계, 의사의 진료관계 등), ③ 형식적인 사항을 설명하는 경우(계산관계, 장부·계좌내역의 관련성 등), ④ 장기간에 걸쳐 발생한 당사자 사이의 사실관계를 시간의 경과에 따라 정리하는 경우(부부·친족 간의 소송에서 당사자 본인의 진술 등) 등을 들 수 있다. 선서의무가 없는 점도 고려하여 반대신문권 보장의 필요성이 크지 않은 경우에 활용한다.

다. 시행방식

서면에 의한 증언 방식으로 하기로 결정하기 전에, 법원은 상대방의 이의권을 보장하기 위하여 사전에 상대방에게 의견진술의 기회를 부여하여야 한다. 의견진술의 기회를 주었는데도 이의를 하지 않았다면 증거결정 후에 새삼스럽게 이의하는 것은 허용되지 않는다.

증인조사를 서면에 의한 증언 방식으로 하기로 결정하면 증인을 신청한 당사자에게 증인신문사항을 제출하게 하여야 한다. 증인에게 신문사항 내지 신문사항의 요지를 고지하여야 하기 때문이다.

상대방에게도 증인에게 회답을 바라는 사항을 적은 서면을 제출하게 할 수 있는데(민소규 84조 1항), 상대방의 반대신문권을 보장하기 위한 취지이다.

법원은 상대방의 이의가 있거나 필요하다고 인정하는 때에는 그 증인을 출석·증언하게 할 수 있으므로(민소 310조 2항), 그 절차에서 상대방으로 하여금 반대신문권을 행사하게 하는 것도 물론 가능하다.

증인에게 출석·증언을 갈음하여 서면증언을 명할 때에는, ① 증인에 대한 신문사항 또는 신문사항의 요지, ② 법원이 출석요구를 하는 때에는 법원에 출석·증언하여야 한다는 취지, ③ 제출기한을 정한 때에는 그 취지를 기재하여 증인에게 고지하여야 한다(민소규 84조 2항).

그중 신문할 사항을 고지하는 방식으로는, ① 신청 당사자 및 상대방 당사자가 제출한 증인신문사항을 합쳐서 법원이 새로 증인신문사항을 작성하여 이를 증인에게 보내는 방식, ② 신청 당사자 또는 상대방 당사자가 제출한 증인신문사항을 그대로 증인에게 보내는 방식, ③ 신문사항의 요지만을 보내는 방식[예컨대 “서면으로 증언할 사항: 이 사건 계약 장소에 참여한 경위 및 목격한 사항”] 등이 있으며, 법원이 증인과 증명할 사항의 내용 등을 고려하여 알맞다고 인정하는 방식을 선택하여 시행한다.

서면증언을 명하는 때에는 법원은 원칙적으로 그 서면의 제출기한을 정하여야 하며, 정해진 제출기한은 증인등목록의 증거조사란에 “서면증언(20○○.

○. ○.까지)”으로 기재한다(민사증거목록예규 19조 3항 1호).

증인은 증언할 사항을 적은 서면에 서명날인하여야 한다(민소규 84조 3항). 이러한 서면증언서는 그 증인의 출석·증언을 갈음하는 것으로서 그 진정성립과 기재내용의 진실성을 담보할 필요가 있기 때문이며, 증인진술서에 증인의 서명날인을 요구하는 것과 같은 취지이다.

제26장

증인

[전산양식 A1734] 서면증언요구서

○ ○ 법 원 제○민사부 서면증언요구서

귀하

사 건 20 가
원 고
피 고

신문사항(요지) 별지와 같음

위 사건에 관하여 귀하를 증인으로 채택하여 신문하게 되었습니다. 다만, 귀하에 대해서는 민사소송법 제310조 제1항에 따라 법원에 출석·증언하는 대신 서면증언에 의하기로 하였으므로, 20○○. ○. ○. 까지 별지 신문사항(요지)에 대하여 증언할 사항을 적은 서면을 제출하시기 바랍니다.

20○○. ○. ○.
법원사무관 ㉠

◇ 유 의 사 항 ◇

1. 서면증언서에는 사건번호를 기재하고, 증인이 서명날인하여야 합니다.
※ 구체적 작성례는 뒷면 참조
2. 서면증언서를 제출한 뒤에도 법원으로부터 출석요구를 받으면 법원에 출석하여 증언하여야 합니다(민사소송법 제310조 제2항).

※ 문의사항 연락처: ○○지방법원 제○민사부 법원사무관 ○○○
전화(○○) ○○○ — ○○○○
팩스(○○) ○○○ — ○○○○ e-mail: @scourt.go.kr

민소 309, 310, 311①, 312, 민소규 84②

서 면 증 언

사 건 20 가
원 고
피 고

증인의 인적사항

이 름: 박○○

생년월일: 1972. 3. 3.

주 소: 서울 00구 00로 000

전화번호: 02-000-0000(휴대폰 010-0000-0000)

1. 본인이 증언할 사항은 첨부한 서면의 해당 조항 여백에 직접 기재하였습니다.
2. 본인이 기재한 내용은 모두 진실임을 서약하며, 법원이 출석요구를 하는 때에는 법정에서 출석하여 증언할 것을 약속합니다.

※ 첨부: 신문사항에 대한 답변서

20○○. ○. ○.

증인 (서명) 인

○○지방법원 제○민사부 앞

라. 제출 후의 절차

서면증언서가 법원에 제출되면 참여사무관은 제출사실과 제출일자를 증인 등목록의 ‘증거조사’란에 기재한다(민사증거목록예규 19조 3항 1호).

법원에 제출된 서면증언은 변론기일에 현출됨으로써 증언으로서의 효력을 갖는다. 그 현출절차는 법원이 서면증언의 도착사실을 고지하고 당사자들에게 그에 대한 의견진술의 기회를 부여하는 방식으로 하고, 신청한 당사자가 이를 원용하겠다고 기일에서 진술할 필요는 없다.

서면증언을 검토하여 증인에게 출석·증언을 명하는 것은 새로운 증거결

정이 아니라 이미 채택된 증인에 대한 조사방법만 변경하는 것으로서 법원의 직권판단 사항에 속한다(민소 310조 2항 참조). 따라서 서면증언의 현출절차에서 상대방이 이의하더라도 이는 법원의 직권발동을 촉구하는 의미에 불과하므로 그 이의를 받아들이지 않는 경우에는 변론조서에 이의한 취지만 기재하면 되고 법원의 판단을 기재할 필요는 없다. 그러나 법원이 상대방의 이의사유 등을 참작하여 증인으로 하여금 출석·증언하게 하는 때에는 이에 따른 증인 출석요구절차와 당사자의 증인신문 준비 등 후속절차의 진행을 명확히 하기 위하여 그 취지를 당사자에게 고지하고 변론조서에도 기재함이 타당하다. 이 경우 증인이 출석·증언할 기일은 증인등목록의 서면에 의한 증언 방식으로 채택할 때 기재한 곳의 ‘비고’란에 기재하면 된다(민사증거목록예규 20조 10호).

[조서 기재례]

재판장

증인 ○○○의 서면증언서 도착 고지

피고 대리인

…… (사유) ……라고 이의 진술

재판장

증인 ○○○으로 하여금 출석·증언하게 한다는 결정 고지

법정 외에서 법원이 필요하다고 인정하여 증인으로 하여금 출석·증언하게 하기로 결정하는 경우에는 서면증언서 표지 등 적당한 여백에 재판장이 “출석증언 결정 재판장 (인)”으로 기재·날인하거나 전자기록의 증인등목록 비고란에 그 취지를 기재하고(변론준비절차가 종결되기 전에 결정을 하는 경우에 수명법관이 지정되어 있으면 수명법관 명의로 표시함이 타당하다), 증인에게 출석요구서를 송달한다. 그리고 그 취지를 양쪽 당사자에게 적당한 방법으로 고지하여 사전에 증인신문을 준비할 수 있도록 조치하여야 한다.

제4절 증인에 대한 출석요구 및 출석확보

1. 증인에 대한 출석요구

가. 출석요구의 방식

증인조사를 증인진술서 제출 방식이나 증인신문사항 제출 방식으로 하는 경우에는 채택된 증인에 대하여 출석요구서를 송달하여야 하는데, 그 출석요구서[전산양식 A1630, A1630-1(중계시설), A1630-2(화상장치)]는 부득이한 사정이 없는 한 출석할 날보다 2일 전(예컨대 기일이 7. 29. 14:00이면 7. 26. 24:00까지)에 송달되어야 한다(민소규 81조 2항).

출석요구서에 기재할 사항은 당사자의 표시, 신문사항의 요지, 출석하지 아니하는 경우의 법률상 제재 등으로서 민사소송법 309조와 민사소송규칙 81조 1항에 규정되어 있다(외국에서 송달할 출석요구서에는 과태료, 구인 또는 감치를 할 수 있다는 취지의 제재문구를 삭제하여야 한다. 민사공조예규 12조). 신문사항의 요지를 출석요구서에 직접 기재하는 대신 증인신문사항을 별지로 첨부할 수도 있다. 증인진술서 제출 방식에 의하여 증인조사를 하는 경우에는 출석요구서에 신문사항의 요지나 증인진술서 사본을 별지로 첨부할 필요는 없다.

증인이 출석요구를 받고 기일에 출석할 수 없을 경우에는 바로 그 사유를 밝혀 법원에 신고하여야 한다(민소규 83조). 신고를 하지 아니하는 경우에는 불출석에 정당한 사유가 없는 것으로 인정되어서 과태료 등 법률상 제재를 받을 수 있으므로, 충분한 소명자료를 첨부하여 불출석신고서를 제출해야 한다.

출석요구서가 송달불능되거나 출석요구를 받지 아니한 증인이 임의출석한 경우에 출석요구서를 송달받았다는 내용의 영수증을 작성·제출하게 할 필요는 없고, 단지 변론조서에 “증인 ○○○ [(송달불능) 또는 (미송달)] 임의출석”이라고 기재하면 된다.

[전산양식 A1630] 증인출석요구서

제26장

증인

○ ○ 법 원

증인출석요구서

사 건 20○○가단○○ 손해배상(기)

원 고 ○○○

피 고 ○○○

신문사항요지 별지와 같음(이미 증인진술서나 증언을 같음하는 서면을 제출한 때에는 그와 관련된 내용)

위 사건의 사실관계 등을 파악하기 위하여 귀하를 민사소송법 제303조(증인의 의무)에 따라 증인으로 채택하여 신문하게 되었으므로, 아래의 일시·장소에 출석하여 주시기 바랍니다.

일시: 20 . . . : (소요예상시간 00분)

장소: ○○지방법원 ○○호 법정

20○○. ○○. ○○.

법원주사 ○○○ 인

◇ 유 의 사 항 ◇

1. 법원은 특별한 규정이 없으면 누구든지 증인으로 신문할 수 있습니다(민사소송법 제303조).
 2. 부득이 위 기일에 출석할 수 없는 경우에는 그 사유를 밝혀 신속히 신고하시기 바랍니다. 멀리 떨어진 곳에 거주하여 출석이 현저히 불편하다고 인정되는 경우에는 거주지 근처 법원에 출석하여 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 증인신문을 진행하는 것도 가능하오니(민사소송법 제327조의2), 불출석사유와 함께 이러한 방식의 증인신문을 희망하는지 여부도 밝히시기 바랍니다.
 3. 정당한 사유 없이 기일에 출석하지 아니한 때에는 법원은 500만 원 이하의 과태료를 부과하고 강제구인 할 수 있으며, 과태료를 부과 받고도 정당한 사유 없이 다시 출석하지 아니한 때에는 7일 이내의 감치에 처할 수 있습니다. 또한, 법원은 위와 같은 불출석으로 인한 소송비용의 부담을 명할 수 있습니다(민사소송법 제311조, 제312조).
 4. 출석할 때에는 본인 확인 및 증인여비지급을 위하여 신분증, 도장 및 계좌번호를 준비하고, 이 사건에 관하여 법원에 제출할 서면이 있는 경우에는 사건번호(20○○가단○○)를 기재하시기 바랍니다.
 5. 대한민국법원 앱(아래 QR코드)이나 대한민국법원 홈페이지(www.scourt.go.kr) '나의 사건검색'을 이용하시면 재판기일 등 각종 정보를 편리하게 열람할 수 있습니다.
 6. 사건진행에 관하여 전화안내를 받고자 하는 경우에는 '(02) 3480-1100[또는 '각급 법원 대표번호']'를 이용하실 수 있습니다.
- ※ 주차시설이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

※ 그 밖의 문의사항 연락처: ○○지방법원 제○단독 법원주사 ○○○

전화:

팩스:

e-mail:

나의 사건검색 QR코드



나. 증인 여비의 예납 및 대동증인과 관련된 문제

채택된 증인에 대하여 출석요구를 하기 위하여 당사자 또는 대리인은 증인의 여비 등 비용을 예납하여야 한다. 증인신청서를 제출할 때 여비를 예납할 수도 있고(민소규 77조 2항), 증거채택이 된 후 증인진술서나 증인신문사항을 제출하는 때 또는 법원이 정하는 기간 안에 여비를 예납해도 된다. 증인으로부터 여비포기서를 받아 제출하였다면 그 비용을 예납하지 않을 수 있다. 여비에 관하여 자세한 것은 제5절 9.를 참조.

종래 실무상으로 증인을 신청한 당사자 또는 대리인이 여비를 예납하는 대신에 증인신청서에 ‘여비직불, 증인대동’이라는 취지로 기재하고, 이에 따라 법원도 증인을 따로 소환하지 않고 대리인 등에게 증인의 출석확보를 맡기는 방식으로 운영하는 사례가 적지 아니하였다. 그러나 이러한 방식은 ① 증인의 출석 여부를 전적으로 대리인 또는 당사자의 의사나 노력 여하에 맡기게 되고, ② 증인이 불출석한 경우에도 과태료 등의 제재를 가할 수 없게 되는 점 등에서 증인에 대한 출석확보가 중요시되는 집중증거조사방식에 적합하지 아니하므로 원칙적으로 허용되어서는 안 될 것이다. 따라서 증인 신청인이 여비직불 취지로 신청했더라도 참여사무관은 신청인에게 증인 명의의 여비포기서를 붙이거나 여비를 예납하도록 한다. 또한 증인 신청인이 증인대동의 취지로 신청했더라도(증인 명의의 여비포기서까지 첨부되어 있는 경우에도) 법원으로서의 신청인의 증인대동 여부와 상관없이 증인에 대한 출석요구절차를 실시하는 것이 바람직하다.

증인에 대한 여비 예납절차가 이행되지 아니하거나 증인진술서 또는 증인신문사항이 정해진 기간 내에 제출되지 아니하는 때에는 참여사무관은 즉시 그 이행을 촉구하고, 대리인 등이 이에 응하지 아니하는 때에는 바로 재판장에게 보고하여 그 지시에 따라 처리하여야 한다. 증인신문사항이 제때 제출되지 않는 곤란을 예방하기 위하여 이를 미리 제출토록 명하고, 그 제출된 것을 검토한 후에 비로소 증인신문할 다음 기일을 정하는 실무례도 있다.

2. 증인의 출석확보를 위한 노력

가. 취 지

집중증거조사를 실시하기 위해서는 증인의 출석확보가 전제되어야 하므로 이를 위한 노력이 중요하다. 민사소송규칙은 75조 2항에서 “증인신문을 신청하는 때에는 증인의 출석을 확보하기 위한 협력방안을 밝혀야 한다.”라고 규정하고, 82조에서 “증인이 채택된 때에는 증인신청을 한 당사자는 증인이 기일에 출석할 수 있도록 노력하여야 한다.”라고 규정하여 신청 당사자의 출석확보를 위한 노력의무를 명시했다. 다만 당사자와 신분적·경제적 관계가 밀접하지 아니한 중립적 증인, 사건의 귀추에 관심이 없거나 시간을 내기가 어려운 것으로 보이는 증인, 양쪽 당사자 모두와 깊은 이해관계를 가지고 있어서 증언에 곤란을 느끼거나 피고로 되어 있지는 않지만 실질적으로는 책임을 추궁당할 입장에 있는 증인 등은 당사자에 의한 출석확보의 노력에도 한계가 있다. 따라서 그러한 증인이 채택된 경우에는 법원도 출석확보를 위하여 적극적인 노력을 기울여야 한다. 비디오 등 증계장치·인터넷 화상장치에 의한 증인신문이 기일 공전 방지에 도움이 될 수 있으니 활용할 만하다.

증인의 출석확보는 집중증거조사기일의 원활한 진행을 위하여 필수불가결한 것이므로 법원 및 당사자 또는 대리인은 증인신청으로부터 신문에 이르는 각 단계에서 각별한 관심을 가지고 서로 협력하여야 한다.

나. 증인신청의 단계

이 단계에서는 증인에 관한 정보를 충분히 입수하여 기일 전에 출석 여부를 확인할 수 있도록 함과 아울러 증인의 출석확보를 위한 신청 당사자의 협력방안을 마련해 둘 필요가 있다. 증인신청서에 증인의 이름·주소·직업 이외에 증인의 전화번호 등의 연락처를 기재하게 하고 증인의 출석을 확보하기 위한 협력방안을 밝히도록 한다(민소규 75조 2항).

다. 증인채택의 단계

증인을 채택하는 단계에서는 대리인 등에 대하여 증인의 출석 가능 여부를 미리 확인하고, 대리인 등에 대하여 기일의 중요성 및 불출석에 따른 불이익을 사전 고지하여야 한다. 특히 의사 등 전문직 종사자를 증인으로 채택하는 경우에는 대리인으로 하여금 그 일정을 바로 확인하고 사정이 있는 때에는 법원에 신속하게 연락을 하도록 하여 신문기일을 변경하거나 대체증인을 확보하는 등의 조치를 취하여야 한다. 증인에 대한 연락·통지 수단을 확보하기 위하여 필요한 경우에는 주민센터 등 공공기관이나 전기통신사업자 등에 대한 사실조회 등을 통하여 주소와 휴대전화번호를 파악할 수 있다. 증인채부를 판단할 당시에 증인에 대한 통지가능성, 출석가능성이 확보되지 않았을 경우에는 해당 증인의 중요도 등을 감안하여, 일정한 기한(가령, 다음 기일)까지 증인신문할 수 없으면 증인신청을 철회하거나 채택을 취소하는 내용의 절차협의를 하고 그 협의결과를 조서에 기재하고 증인을 채택하는 실무운영도 고려해 볼 수 있다.

라. 출석 가능 여부의 확인

참여사무관은 증인신문기일의 약 1주 전에 대리인을 통하거나 증인에게 직접 연락하여 출석 가능 여부를 확인한 후 재판장에게 보고하여야 하고(사건관리예규 13. 라.), 기록에도 출석 확인 사실을 표시하여 두는 것이 후에 과태료 재판 등과 관련한 자료의 확보라는 차원에서 바람직하다.

출석 여부의 확인 결과, 증인이 불출석 의사를 밝히는 경우에는 그 이유를 구체적으로 확인하여 적절한 조치를 취하고 재판장에게 조치내역을 보고한다. 불출석의 이유가 질병 등 정당한 사유에 해당된다고 판단되는 때에는 진단서 등 소명자료가 첨부된 불출석 신고서(민소규 83조)를 제출하도록 요구하고(불출석 신고서를 제출하지 아니하면 과태료가 부과될 수도 있음을 아울러 고지한다), 언제쯤 출석할 수 있는지 여부도 확인한다. 뚜렷한 불출석 사유를

설명하지 아니하는 경우에는, 누구든지 사건의 진실 규명과 조기 종결을 위하여 민사소송법에 따른 증인의무가 있다는 취지를 증인에게 설명하고(민소 303조 참조), 정당한 사유 없이 불출석하면 소송비용의 부담과 함께 과태료·감치 등의 제재를 받을 수 있음을 고지하여야 한다.

제26장

증인

3. 증인 불출석에 따른 기일의 운영

증인의 일부 또는 전부가 불출석하거나 불출석할 것으로 예상되는 경우에 재판부가 선택할 수 있는 대응방안으로는, ① 양쪽 당사자와의 사전협의를 통한 대체증인의 확보, ② 신문의 필요성이 덜한 경우에는 증거결정을 취소하거나 증거신청을 취하하도록 유도하고 출석 증인만을 신문하는 방안, ③ 출석한 증인만 신문하고 다음 기일로 속행하는 방안, ④ 전체 기일을 변경하여 다음 기일에 일괄 신문하는 방안 등을 들 수 있다.

이러한 방법 중 어느 것을 선택할 것인지는 불출석 증인의 중요도, 불출석의 사유와 그 횟수, 나머지 증인들의 출석 상황 등을 고려하여 결정할 수밖에 없을 것이다. 다만 동일한 쟁점에 관한 복수의 증인 중 일부가 불출석한 경우에는 ③방식보다는 ④방식을 택하는 것이 적절한 경우가 많을 것이며, 또한 ③방식에 따라 다음 기일에 증인신문을 계속하는 때에는 민사소송규칙 72조의 취지에 따라 가능한 최단기간 안의 날짜를 신문기일로 지정함으로써 효율적인 증인신문이 이루어지도록 하여야 한다.

또한 불출석을 이유로 그 증인에 대한 신문기일을 부득이 연기하는 때에는 당사자나 대리인에 대하여 향후 절차가 보다 엄격하게 진행됨을 주지시키고, 특히 당사자의 지배영역 내에 있어서 쉽게 출석확보를 할 수 있다고 판단되는 증인(가족, 회사직원 등) 때문에 기일공전이 거듭되는 경우에는 채택 결정을 취소하는 등 집중증거조사를 관철시키기 위한 엄격한 조치가 필요하다.

4. 불출석 증인에 대한 제재

가. 개 요

불출석 증인에 대한 제재수단으로서는 소송비용 부담, 과태료 부과 및 감치제도가 있고, 강제적 출석확보 수단으로서 구인이 있다. 민사소송법은 법원에 불출석 증인에 대한 강력한 제재수단의 행사 권한을 수여하는 한편, 변론준비절차를 통하여 쟁점정리를 마친 사건에 대해서는 원칙적으로 1회 변론기일에 변론을 종결할 수 있는 기일운영을 요구하고 있다(민소 287조 1항, 293조 참조). 이는 변론기일의 원활한 운영을 저해하는 증인에 대해서는 제재수단을 적극 행사하여야 할 책무를 법원에 부여한 취지로 이해된다.

나. 소송비용부담, 과태료의 부과 및 감치제도의 효율적 운영

증인이 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 때에는 법원은 결정으로 증인에게 이로 말미암은 소송비용을 부담하도록 명하고 500만 원 이하의 과태료에 처할 수 있으며(민소 311조 1항), 증인이 불출석에 따른 과태료재판을 받고도 정당한 사유 없이 다시 출석하지 아니한 때에는 7일 이내의 감치에 처할 수 있다(2항).

소송비용의 부담을 명하는 결정과 과태료를 부과하는 결정은 수소법원의 재량에 속하며, 양자를 함께 할 수도 있고 그중 하나만 선택하여 할 수도 있다는 것이 일반적인 견해이다. 증인에게 부담시킬 소송비용의 예로는 증인에 대한 출석요구서 송달비용, 당사자 또는 대리인이 그 기일에 출석하기 위하여 쓴 여비·일당 등을 들 수 있다.

소송비용 부담의 재판과 과태료 재판은 수소법원이 관할하고(민소규 85조 1항), 이에 따른 재판절차에 관하여는 비송사건절차법 248조와 250조(다만 248조 3항 후문과 검사에 관한 부분을 제외한다)의 규정을 준용한다(민소규 85조 2항). 이러한 결정들은 집행권원이 되므로(민집 56조 1호), 조서에 기재하는 것보다는 별도의 서면으로 작성·고지하는 것이 적당하다. 이 결정에 대

하여는 즉시항고를 할 수 있으나, 이 경우 집행을 정지시키는 효력은 없다(민소 311조 8항). 과태료 재판이 확정되면 집행이 되게끔 검찰에 송부해야 한다.

증인에 대한 과태료재판 및 감치재판에 관한 자세한 내용은 제7절, 제8절 참조.

다. 구인

증인이 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 경우에는 법원은 증인을 법정이나 그 밖의 신문장소로 구인하도록 명할 수 있다(민소 312조 1항). 구인을 명하는 경우에도 출석요구서는 별도로 송달하여야 한다. 증인의 구인에 관하여는 형사소송법과 형사소송규칙 중 구인에 관한 규정이 준용되고 있는데(민소 312조 2항, 민소규 87조, 형소 69조 이하), 이 경우에 사용할 양식으로 구인장[전산양식 A1633]이 마련되어 있다.

구인장에는 재판장 또는 수명법관이 서명날인(기명날인은 안 됨)하여야 하며(형소 75조 1항 준용), 그 집행은 검사의 지휘에 의하여 사법경찰관리가 담당하는 것이 원칙이므로(형소 81조 1항) 구인장의 원본을 검사에게 송부하여야 하는데(형소규 48조의 준용), 구인장집행의뢰서[전산양식 A1634]와 함께 송부한다. 이 구인장집행의뢰서에는 기명날인하면 된다.

현행 형사소송규칙상 구인에 관한 규정은 68조 2항(구속영장의 기재사항)이 있고, 69조에 의하여 준용되는 48조(검사에 대한 구속영장의 송부), 49조(구속영장집행 후의 조치) 등이 있는데, 이 조항들이 증인에 대한 구인절차에 준용된다.

또한, 집행관법 6조 3호에 의하면 집행관은 법원의 명령이 있는 경우에는 영장의 집행사무를 처리할 직무상 의무를 지므로 법원은 소속 집행관에게 구인장의 집행을 명할 수 있다고 해석된다. 이 경우에도 재판장 명의로 구인장 집행의뢰공문을 집행관에게 송부하되, '수신'란에는 '○○법원 소속 집행

관'으로 기재한다. 구인장을 집행한 집행관은 수수료는 지급받지 못하고 여비·숙박료 등 비용만을 지급받을 수 있는데(집행관법 20조), 이 비용액은 신청당사자로부터 예납받아야 한다.

증인이 한번 불출석하면 곧바로 과태료 또는 구인의 조치를 취하거나, 필요한 경우에는 과태료를 부과함과 아울러 구인장도 발부함으로써, 집중적인 증거조사가 이루어질 수 있도록 노력하여야 한다.

제5절 증인신문의 방법

1. 신문전 절차

가. 증인의 동일성 확인

재판장은 증인을 신문하기에 앞서 증인으로부터 주민등록증 등 신분증을 제시받거나 그 밖의 적당한 방법으로 증인임이 틀림없음을 확인하여야 한다(민소규 88조). 과거에는 재판장이 증인의 이름·주민등록번호·주소 및 직업을 물어서 증인임이 틀림없음을 확인하는 인정신문제도가 실시되었으나, 그 과정에서 증인의 사생활이 침해되고 개인정보가 유출될 염려가 있어 2006년 민사소송규칙 개정으로 인정신문제도는 폐지되었다.

참여사무관은 증인신문조서[전산양식 A1656] 중 '증인'란에 증인의 이름·생년월일·주소를 기재한다. 이때 가능한 한 주민등록증, 운전면허증, 그 밖의 신분증을 제시하게 하여 출석한 자가 채택된 증인과 일치하는지 여부를 확인하여야 한다. 가급적 그 주민등록번호를 재판사무시스템에 입력·저장해 둘 필요가 있는지도 고려해야 한다. 주민등록증 등 신분증을 지참하지 아니한 증인에 대하여는 상대방 당사자에게 동일인 여부를 물어서 상대방이 이의를 제기하지 아니하면 증인신문을 허용하는 것이 통상적인 실무이다.

나. 선 서

재판장은 증인이 선서무능력자(16세 미만인 사람 또는 선서의 취지를 이해하지 못하는 사람)인 경우(민소 322조), 선서를 면제한 경우(323조) 또는 선서거부권을 행사한 경우(324조) 이외에는 증인신문을 개시하기 전에 선서의 취지를 밝히고 위증의 벌에 대하여 경고한 후(320조) 증인으로 하여금 선서서를 소리 내어 읽고 선서서에 기명날인 또는 서명하게 하여야 하며, 증인이 선서서를 읽지 못하거나 기명날인 또는 서명하지 못하는 경우에는 참여한 법원사무관등이나 그 밖의 법원공무원으로 하여금 이를 대신하게 하여야 한다(321조 3항). 증인이 인장을 지참하지 않아 기명날인을 할 수 없고 스스로 서명할 수도 없는 경우에는 무인을 하도록 할 수 있을 것이나 증인이 서명을 할 수 있다면 무인을 요구하여서는 아니 된다.

증인은 선서함에 있어서 일어서서 엄숙하게 하여야 한다(민소 321조 4항). 민사소송법은 기립할 자의 범위를 증인으로 국한하고 있으므로, 그 밖의 사람은 일어설 필요가 없다. 증인을 선서시킨 경우에는 그러한 뜻을 조서에 기재하여야 한다(154조 2호).

증인이 어느 사건에 관하여 한번 선서를 한 경우에는 예정된 신문을 끝내지 못하여 다음 기일에 속행하는 때는 물론이고 일단 신문을 종료하고 새로 증인으로 채택하여 신문하는 때에도 전후의 신문사항이 전혀 무관한 경우가 아닌 한 다시 선서를 시킬 필요가 없다. 이때에는 전에 행한 선서의 효력이 유지됨을 알려주기만 하면 족하다(증인신문조서에는 “재판장, 제○차 변론기일에 행한 선서의 효력이 유지됨을 알려 주었다.”라고 기재한다).

증인에 대한 선서의 취지 명시와 위증의 벌의 경고는 “증인은 이제 신문에 대하여 증인이 경험한 바를 사실 그대로 말하겠다는 맹세를 하여 주시기 바랍니다. 증인이 맹세한 후에 거짓을 말하면 위증죄로 처벌받을 수 있습니다.” 등으로 하는데, 증인이 위압감과 모욕감을 느끼지 않도록 배려하여야 한다.

동일 사건의 여러 증인을 한 기일에 신문할 경우에도 선서는 증인마다 시키는 것이 원칙이다. 그러나 기일의 효율적 진행을 위하여 여러 증인을 동시에 불러 각 증인의 인적사항을 확인하고 한꺼번에 위증의 벌을 경고한 다음 그중 1인에게만 대표로 선서서를 낭독하게 하고 다른 증인들은 선서서를 들고 묵독하게 하여도 무방하다. 다만 증인신문을 녹음하여 그 녹음물이 증인신문조서의 일부가 되는 경우에는 해당 녹음물이 증인별로 분리 저장되는 관계로 위 원칙에 따라 각 증인을 신문하기에 앞서 개별적으로 인적사항을 확인하고 위증의 벌을 경고한 다음 선서를 시키는 것이 바람직하다.

법원은 특별한 사유가 있는 때에는 증인신문을 한 후에 증인에게 선서를 하게 할 수도 있다(민소 319조 단서). 특별한 사유로는, 증인이 언뜻 보아서는 선서의 취지를 이해할 능력이 있는지 여부를 알 수 없고 신문을 해 보아야 알 수 있다고 판단되는 경우, 증언거부권이나 선서거부권 유무에 다름이 있지만 증인이 우선 신문에 응하고 법원이 증인신문에서 드러난 내용까지 고려하여 신문종료 직후에 그 유무에 관한 판단을 고지하기로 하여 신문을 일단 진행하는 경우 등을 들 수 있다. 증인신문을 마친 후 선서를 하게 하는 경우에는 증인의 선서문언을 과거형으로, 즉 “사실 그대로 말하고”를 “사실 그대로 말하였고”로, “거짓말이 있으면”을 “거짓말이 있었으면”으로 바꾸어야 한다.

다. 증언거부와 선서거부 등

(1) 사유

증언거부의 사유는, 첫째 증언이 증인 자신이나 증인의 친족 또는 이러한 관계에 있었던 사람, 증인의 후견인 또는 증인의 후견을 받는 사람이 공소제기되거나 유죄판결을 받을 염려가 있는 사항 또는 자신이나 그들에게 치욕이 될 사항에 관한 것인 때(민소 314조), 둘째 변호사 등 특수 직책에 있거나 그러한 직책에 있었던 사람이 직무상의 비밀에 속하는 사항에 대하여 신문

을 받을 때(315조 1항 1호), 셋째 기술 또는 직업의 비밀에 속하는 사항에 대하여 신문을 받을 때이다(2호). 다만 증인이 비밀을 지킬 의무가 면제된 경우에는 증언을 거부할 수 없다(315조 2항).

선서거부의 사유는 증인 자신 또는 위 첫째의 증언거부사유 해당자와 현저한 이해관계가 있는 사항에 관하여 신문을 받을 때이며(민소 324조), 이때에는 증언 자체는 거부할 수 없고 선서만을 거부할 수 있을 뿐이다.

어느 경우이든 위 거부사유 해당자가 사건의 당사자와 일치할 것을 요하지 않는다.

(2) 거부권 고지의 요부

증언거부권이나 선서거부권의 고지에 관하여 명문규정이 없으므로 법원이 이를 증인에게 고지할 의무가 없으며, 고지하지 아니하였다 하여도 위법이 아니다(대법원 1971. 4. 30. 선고 71다452 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009도14928 판결). 그러나 증인과 당사자 사이에 친족관계 등이 있는지 여부를 물어 친족 등의 관계에 있을 때에는 선서거부의 의사 유무를 확인하는 것이 바람직하다.

(3) 거부권이 행사된 경우의 처리

증언거부권 또는 선서거부권을 행사한 증인은 거부의 사유를 소명하여야 한다(민소 316조, 326조). 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여야 하므로(299조 1항) 미리 서증 등을 준비하여 나온 경우가 아니면 소명이 곤란하겠지만, 제출된 신문사항과 증인의 주장 및 당사자의 진술 등을 대조하여 거부사유를 인정할 수 있다면 소명이 이루어진 것으로 볼 수 있을 것이다.

증언거부 또는 선서거부가 옳은지에 관하여는 법원이 그 증인을 신청한 당사자를(필요하다면 상대방도) 심문하여 재판한다(민소 317조 1항, 326조). 선서거부의 경우 뚜렷한 소명방법이 없는 것처럼 보이더라도 바로 선서거부의 신청을 배척하지는 않은 채 선서를 시키지 않고 신문을 다 마친 후에 선서거부의 사유가 인정되는지 여부를 판단하는 방법도 있다.

증언거부가 이유 있다고 인정하는 때에는 증인신문조서에 “증인, … 라는 사유로 증언을 거부, 재판장, 당사자를 심문한 후 민사소송법 제○조 제○호의 규정에 해당함을 인정하고 증언거부가 이유 있다는 결정 고지”라고 기재하고 (인쇄된 문구는 지운다), 기본조서에는 “출석한 증인 별지 조서와 같이 증언 거부”로 기재하며, 증인등목록에는 ‘증거조사’란의 증인신문기일 옆에 “(증언 거부)”라고 기재한다. 한편 선서거부가 이유 있다고 인정하는 때에는 따로 만들어져 있는 증인신문조서(선서생략)[전산양식 A1657] 양식을 이용하면 된다 (다만 위 양식의 괄호 안 부분을 삭제한다).

반면 증언거부 또는 선서거부가 이유 없다고 인정하는 때에는 증인신문조서에 “증인, … 라는 사유로 증언을(선서를) 거부, 재판장, 당사자를 심문한 후 증언(선서)거부가 이유 없다는 결정 고지”라고 기재한다.

한편, 이상의 각 결정은 위와 같이 조서에 기재하지 않고 별도의 서면으로 작성하여 고지하여도 무방하다. 위 각 결정에 대하여는 증인신문을 신청한 당사자 또는 증인이 즉시항고를 할 수 있다(민소 317조 2항, 326조). 이러한 즉시항고는 집행정지의 효력이 있으므로(447조), 그 결정의 확정 전에는 증인신문의 해당 부분을 실시할 수 없을 것이다.

(4) 선서의 면제

민사소송법 314조에 해당하는 증언거부사유가 있는 증인이 증언거부권을 행사하지 않은 경우에 그 증인을 신문함에는 선서를 시키지 아니할 수 있다(민소 323조). 그러한 증인에게 선서까지 시키고 진실을 증언하라고 부담을 지우는 것은 인정상 가혹한 경우가 있을 수 있음을 고려한 것이다. 법원이 직권으로 하는 것이므로 당사자에게 신청권이 없음은 물론이고 그 결정에 대하여 불복할 수도 없다. 이때에는 증인신문조서(선서생략)[전산양식 A1657] 양식의 괄호 안의 문구만을 살리고 나머지는 지워서 “재판장, 증인이 민사소송법 제314조의 규정에 해당하므로 동법 제323조에 따라 선서를 시키지 아니하였다.”로 만들어야 한다.

(5) 선서거부가 이유 없는 경우의 신문 거부

선서거부가 이유 없다는 재판을 한 경우에는 선서를 시키고 신문하는 것이 원칙이지만, 양쪽 당사자가 이의하지 않는 한 선서 없이 신문을 행하여도 위법이 아니며 유효한 증언이 된다.

(6) 제 재

증언거부가 이유 없다고 한 재판이 확정된 뒤 증인이 끝내 증언을 거부하는 경우(민소 318조), 선서거부가 이유 없다고 한 재판이 확정되었는데도 증인이 끝내 선서를 거부하는 경우(326조)에는 법원은 결정으로 이로 말미암은 소송비용을 부담하도록 명하고 500만 원 이하의 과태료에 처한다(311조 1항).

2. 증인신문의 진행

가. 신문의 순서

(1) 개요

증인신문은 증인을 신청한 당사자가 먼저 하고 다음에 다른 당사자가 하고 그 후에 재판장이 신문한다(민소 327조 1항, 2항). 원칙적인 순서는 ① 증인신문의 신청을 한 당사자의 신문(주신문), ② 상대방의 신문(반대신문), ③ 증인신문신청을 한 당사자의 재신문(재주신문)의 순으로 진행된다. 이후의 신문(재반대신문, 재재주신문 등)부터는 재판장의 허가를 얻은 경우에 한하여 허용된다(민소규 89조 2항). 이때 조서에 ‘재판장의 허가를 얻어’라고 기재할 필요는 없다.

재판장의 허가를 받을 필요 없이 재주신문까지 진행할 수 있도록 한 취지는 증인신문신청을 한 당사자의 신문권을 보다 확대하고, 적대적 증인에 대하여 증인신문을 신청한 당사자에게 그 증인의 증명력을 다투기 위한 신문(민소규 94조)을 원활히 보장하는 의미를 지닌 것이다.

재판장은 증인이나 증명할 사항에 비추어 알맞다고 인정하는 때에는 주신문에 앞서 증인에게 증인과 그 사건과의 관계와 쟁점에 관하여 증인이 알고

있는 사실을 개략적으로 진술(모두진술)하게 한 후, 당사자들에게 신문기회를 부여하는 방식으로 운영할 수 있다(민소규 89조 1항 단서). 이는 당사자가 주 신문을 하기에 앞서 증인에게 사건에 관한 간략한 모두진술을 하게 함으로써 사건의 쟁점을 명확하게 하고 증인의 기억을 환기시키는 것이 유용한 경우가 많다는 점을 고려한 것이다. 또한 당사자 본인소송의 경우 등에는 교호 신문 방식이 오히려 진실발견이나 절차의 원활한 진행에 지장을 주는 수도 있으므로, 이러한 경우에는 당사자의 의견을 들어 신문의 순서를 바꾸고 재판장이 증인신문을 주도하는 방식도 적극 활용하여야 한다(민소 327조 4항).

(2) 주신문

당사자 쌍방이 공동으로 신문신청을 한 동일한 증인의 신문 순서는 당사자 쌍방이 협의하여 정할 수도 있지만 재판장이 정하는 것이 보통이다. 이때에는 증인신문사항의 내용, 증인과 당사자의 관계 등을 고려하여 주된 신문을 함이 적절하다고 인정되는 당사자에게 주신문을 하게 함이 타당하다. 증인신문을 신청한 당사자가 신문기일에 출석하지 아니한 경우에는 다음 기일로 연기할 수 있으나, 재판장이 그 당사자 대신 신문을 할 수 있다(민소규 90조).

주신문은 증명할 사항과 이에 관련된 사항에 관하여 하는데(민소규 91조 1항), 관련된 사항은 간접적으로 관련된 사항도 포함되며 증인의 증명력을 보강하기 위하여 필요한 사항도 포함된다.

주신문에서는 신문을 하는 사람이 희망하거나 기대하는 답을 암시하여 질문하는 유도신문은 원칙적으로 금지된다. 허위의 증언을 유도할 위험성이 많기 때문이다. 다만, 유도신문의 필요가 있고 그 폐해가 없거나 비교적 적은 경우에는 허용되는데, 구체적으로 ① 증인과 당사자의 관계, 증인의 경력, 교우관계 등 실질적인 신문에 앞서 미리 밝혀둘 필요가 있는 준비적인 사항에 관한 신문의 경우, ② 증인이 주신문을 하는 사람에 대하여 적의 또는 반감을 보이는 경우, ③ 증인이 종전의 진술(법관 앞에서의 진술에 한정하지 않음)과 상반되는 진술을 하는 때에 그 종전 진술에 관한 신문의 경우, ④ 그 밖

에 유도신문이 필요한 특별한 사정이 있는 경우(예컨대 복잡한 거래내용 등에 관하여 증인이 줄거리를 기억하고 있지만 보다 세부적인 거래내용 등에 관하여 확인할 필요가 있는 경우 등)에는 허용된다(민소규 91조 2항).

재판장은 예외적으로 허용되는 경우를 제외한 유도신문은 제지하여야 하고, 유도신문이 허용되는 경우에도 그 방법이 상당하지 아니하다고 인정하는 때에는 제한할 수 있다(민소규 91조 3항). 재판장은 유도신문에 해당하는 질문이 이미 발설된 후에 개입하기보다는, 신문사항을 검토하여 구두 또는 서면으로 미리 수정명령을 하는 것이 바람직하다. 증인신문을 시작하기 전에 유도신문금지 원칙을 고지해 두는 것도 적절할 것이다.

(3) 반대신문

증인신청을 한 당사자의 상대방이 신문하는 반대신문은 주신문에 나타난 사항과 이에 관련된 사항에 관하여 한다(민소규 92조 1항). 반대신문은 상대방에게 유리한 증언의 증명력, 즉 신빙성을 약화시키기 위하여, ① 증인이 그 사실을 정확히 인식하지 못하였거나 인식할 수 없었던 상황에 있었던 점, ② 증인이 증명할 사실을 지금까지 기억할 것을 기대하기 어렵다는 점, ③ 증인이 신청인 측에 편향된 자세에 있어 중립적으로 진술하기 어렵다는 점, ④ 증인이 사실을 밝히지 않고 거짓 진술을 하고 있다는 점 등을 부각시키기 위한 신문이다.

증인은 반대신문자에 대하여 호의를 갖지 않고 있는 경우가 보통이므로 반대신문에서 필요한 때에는 유도신문을 할 수 있다. 다만 유도신문의 방법이 상당하지 아니하다고 인정되는 때에는 재판장은 이를 제한할 수 있다(민소규 92조 2항, 3항). 또한 반대신문의 기회에 주신문에 나타나지 아니한 새로운 사항에 관하여 신문하고자 하는 때에는 재판장의 허가를 받아야 하며, 그 신문은 그 사항에 관하여는 주신문으로 취급하게 된다(4항, 5항).

주신문과 반대신문에서의 증언내용이 모순될 때에는 재판장이 증언내용을 분명히 밝히는 것이 필요하다.

(4) 재주신문

반대신문이 종료하면 주신문을 한 당사자는 반대신문에서 나타난 사항과 이와 관련된 사항에 관하여 다시 신문할 수 있는데(민소규 89조 1항 3호, 93조 1항), 이러한 재주신문절차는 기본적으로 주신문의 경우와 동일하므로 원칙적으로 유도신문이 금지된다(93조 2항). 또한 반대신문에 나타나지 아니한 새로운 사항에 관하여 신문하고자 할 때에는 재판장의 허가를 받아야 하며, 이 경우에는 그 사항에 관한 주신문으로 보게 되므로 이에 관해서는 다시 상대방에게 반대신문의 기회를 주어야 한다(93조 3항, 92조 4항, 5항).

(5) 보충신문·개입신문 등

재판장은 원칙적으로 양쪽 당사자의 신문이 끝난 후 증인을 신문할 수 있고(민소 327조 2항, 보충신문), 또한 재판장은 필요하다고 인정하면 당사자의 신문 도중에 언제든지 증인을 신문할 수 있다(3항, 개입신문). 그리고 재판장이 알맞다고 인정하는 때에는 당사자의 의견을 들어 주신문·반대신문·보충신문의 순서를 바꿀 수 있다(4항). 합의부원은 재판장에게 알리고 신문할 수 있는데(6항), 재판장의 허가를 받을 필요는 없으며, 조서에는 “판사 ○○○”라고 기재하면 족하고 ‘재판장에게 알리고’를 기재할 필요는 없다. 재판장은 신문내용이나 증언내용이 지나치게 복잡하거나 불분명한 경우에는 신문 도중이라도 증인을 통하여 그 취지를 확인, 보충한 다음 증언내용을 정리함이 바람직하다.

전문심리위원은 재판장의 허가를 받아 증인에게 직접 질문할 수 있다(민소 164조의2 3항).

나. 신문의 방법

(1) 개별적·구체적 신문

증인에 대한 신문은 가능한 한 개별적이고 구체적으로 하여야 한다(민소규 95조 1항). 즉 증인이 답하여야 할 사항을 한꺼번에 포괄적·추상적으로 전부

물어 증인의 답변이 '예'로 끝나게 하여서는 안 되고(장문단답식), 가능한 한 개별적이고 구체적으로 물어 증인의 진술을 통하여 사실을 확인하는 방법(단문장답식)에 의하여 실제적 진실을 발견하여야 한다.

같은 맥락에서, 유도신문 금지의 원칙을 유념해야 한다. 자칫 유도신문이 사실상 허용되거나 방치되면 법관의 인식에 왜곡을 초래하거나 심증형성이 오도될 위험이 있다. 재판장은 당사자·대리인에게 주신문에서의 유도신문은 허용되지 않는 것이 원칙임을 경고하고, 신문사항을 미리 검토하여 유도신문인 신문사항이 있다면 수정을 명해 돕이 바람직하다.

(2) 탄핵신문

주신문·반대신문·재주신문 과정에서 당사자는 증인의 증명력을 다투기 위하여 필요한 사항에 관한 신문을 할 수 있다(민소규 94조 1항). 이러한 탄핵신문은 증인의 경험·기억 또는 표현의 정확성 등 증인의 신빙성에 관련된 사항 및 증인의 이해관계·편견 또는 예단 등 증인의 신용성에 관련된 사항에 관하여 하게 된다(2항). 이러한 사항의 신문도 함부로 증인을 모욕하거나 증인의 명예를 해치는 내용의 신문까지 허용하는 것은 아니므로, 그러한 내용의 신문에 대하여는 당사자나 증인은 이의하면서 재판장에게 필요한 조치를 요청할 수 있고, 재판장은 그러한 내용의 신문을 제한할 수 있다(95조 2항).

(3) 신문의 제한

재판장은 신문이 중복되거나 쟁점과 관계가 없는 경우(민소 327조 5항), 또는 ① 증인을 모욕하거나 증인의 명예를 해치는 내용의 신문, ② 주신문·반대신문·재주신문·증인의 증명력을 다투기 위하여 필요한 사항의 신문에 관한 민사소송규칙 91조 내지 94조의 규정에 어긋나는 신문, ③ 의견의 진술을 구하는 신문, ④ 증인이 직접 경험하지 아니한 사항에 관하여 진술을 구하는 신문을 하는 경우 등에는 이를 제한할 수 있다(민소규 95조 2항 본문). 다만 ② 내지 ④의 신문에 관하여 정당한 사유가 있는 때에는 제한할 수 없는데(2항 단서), 예컨대 감정증인의 성격이 있는 증인이 경험한 사항에 의견

을 더한 진술을 해야 할 경우, 진술의 증명력을 다투기 위하여 증인이 직접 경험하지 아니한 사항에 관해 신문하는 경우 등에는 정당한 사유가 있다고 인정될 여지가 있을 것이다.

(4) 자료의 활용 등

증인의 증언은 법정에 출석하여 말로 하여야 하며 서류에 의하여(즉 서류를 보면서) 진술하지 못하나(민소 331조 본문), 당사자는 재판장의 허가를 받아 문서·도면·사진·모형·장치, 그 밖의 물건을 이용하여 신문할 수 있다(단서, 민소규 96조 1항). 전자기록사건에서는 당사자는 재판장 등의 허가를 얻어 멀티미디어 자료 등 전자문서를 이용하여 증인을 신문할 수 있다(민전규 36조 1항). 이 경우 문서 등이 증거조사를 하지 아니한 것인 때에는 당사자 사이의 공평과 상대방의 신문의 편의 등을 고려하여, 신문에 앞서 상대방에게 열람할 기회를 주어야 하나 상대방의 이의가 없는 때에는 그러하지 아니하다(민소규 96조 2항). 재판장은 조서에 붙이거나 그 밖에 다른 필요가 있다고 인정하는 때에는 당사자에게 문서등의 사본(사본으로 제출할 수 없는 경우에는 그 사진이나 그 밖의 적당한 물건)을 제출할 것을 명할 수 있다(3항).

듣지 못하는 증인에게 서면으로 물은 때 또는 말을 못하는 증인에게 서면으로 답하게 한 때에는 그 자리에 참여한 사람들이 동시에 알게 할 필요가 있으므로, 재판장은 법원사무관등으로 하여금 질문 또는 회답을 기재한 서면을 낭독하게 할 수 있다(민소규 99조).

재판장은 필요하다고 인정한 때에는 증인에게 문자를 손수 쓰게 하거나 그 밖의 필요한 행위를 하게 할 수 있다(민소 330조). 증인신문을 할 때 증인이 자기의 성명이 기재되어 있는 서증의 진정성립을 부정한다든지 하여 필적을 대조하기 위하여 필요한 경우에 증인에게 문자를 손수 쓰게 하거나, 증언의 내용이 말로는 이해하기 어려운 경우 정황을 도면으로 그려서 설명하게 하거나 행동 또는 몸짓으로 표현하여 재연하게 하는 것, 인터넷 화상장치에 의한 증인신문 시 시야 확보 또는 주변상황 확인 등을 위하여 증인의 카

메라를 움직이게 하는 것 등이 그 예이다.

(5) 쟁점별 증인신문

재판장은 정리된 쟁점별로 주신문, 반대신문, 재주신문의 순서에 따라 신문하게 할 수 있다(민소규 89조 3항). 쟁점별 증인신문은 쟁점이 다양하고 복잡한 반면에 쟁점 사이에 밀접한 관련성이 없는 사건에서는 하나의 쟁점에 관하여 주신문, 반대신문, 재주신문을 순서대로 실시하여 그 쟁점에 관한 신문을 일단락 짓고 나서 다음 쟁점에 관한 신문을 순차 진행하는 방식이다. 사건의 쟁점이 구체적으로 부각되고 쟁점을 중심으로 한 효율적이고 입체적인 증인신문이 이루어져 실체적 진실의 발견에 유리할 뿐만 아니라, 증인신문사항 및 증인신문시간을 단축하고 핵심 사항에 대한 신문 누락을 방지할 수 있는 등의 장점이 있다.

(6) 다수당사자 소송의 경우

여러 명의 원고 또는 피고가 공동으로 동일한 증인의 신문을 신청하거나 신문사항에 대하여 이해가 상반되는 관계가 있는 경우에는 각 원고 또는 피고는 저마다 각자의 신문을 한다.

동일한 당사자의 소송대리인이 수인인 경우에는 그중의 1인이 대표로서 증인을 신문하고 다른 소송대리인은 대표자의 신문이 끝난 후에 바로 계속하여 중복되지 않는 범위 내에서 신문을 하는 방법이 적절하다.

원고 또는 피고가 여럿인 사건에서 그중의 당사자 1인만 증인신문을 신청하였고 다른 당사자는 이해가 상반되는 관계에 있는 경우, 통상의 공동소송인 상호 간에도 증거공통의 원칙이 적용되므로 서로 이해가 상반되는 공동소송인 중 1인이 신청한 증인의 증언에 의하여 불리한 사실이 인정될 우려가 있는 다른 공동소송인에게도 신문의 기회를 주는 것이 타당하고, 이 경우 재판장의 재량으로 주신문을 한 후 반대신문에 들어가기 전에 신문하게 한 다든지 또는 반대신문까지 끝난 후에 신문하게 하면 될 것이다.

3. 비디오 등 중계장치에 의한 증인신문

가. 의의

법원은 멀리 떨어진 곳 또는 교통이 불편한 곳에 살고 있거나 그 밖의 사정으로 말미암아 법정에 직접 출석하기 어려운 사람 또는 나이, 심신상태, 당사자나 법정대리인과의 관계, 신문사항의 내용, 그 밖의 사정으로 말미암아 법정에서 당사자 등과 대면하여 진술하면 심리적인 부담으로 정신의 평온을 현저하게 잃을 우려가 있는 사람을 증인으로 신문하는 경우 알맞다고 인정하는 때에는 당사자의 의견을 들어 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하여 신문할 수 있다(민소 327조의2 1항).

증인이 건강, 원격지 거주, 교통편 미비, 생계유지 등의 사정으로 법정에 직접 출석하기 어려운 경우에는 법정출석을 기피하여 증인신문기일이 공전되고 소송이 지연될 수 있다. 또한 증인이 심신상태, 당사자와의 관계 등의 사정으로 법정에서 당사자 등과 대면하여 진술하기 곤란한 경우에는 당사자와 장소적으로 격리된 상태에서 증인신문을 실시하는 방안이 필요하다. 민사소송법은 비디오 등 중계장치에 의한 원격영상증언 제도를 마련하여 일정한 요건하에 법정에 재정한 법관과 쌍방 당사자, 법정 밖의 증인 등 소송관계인 모두가 서로를 인식한 상태에서 영상과 음향의 전송을 통해 증인신문을 할 수 있도록 함으로써 직접심리주의의 한계 내에서 효율적으로 증인신문을 실시할 수 있도록 하고 있다.

나. 의견청취 및 결정

법원은 비디오 등 중계장치에 의한 증인신문 실시 여부를 결정하기 전에 당사자의 의견을 들어야 한다. 기일에 당사자의 의견을 청취할 수 있고 기일외에서 당사자에게 의견조회서(전산양식 A1821)를 보내 의견을 들을 수도 있다. 사안에 따라서는 증인의 의견을 들어볼 수도 있을 것이다(영상재판예규 10조 2항).

법원이 당사자·증인의 의견에 구속되는 것은 아니다. 비디오 등 중계장치에 의한 증인신문을 실시할 것인지 여부는 증인신문의 방식에 속하는 사항으로서 법원이 합리적 재량으로 결정할 문제이고, 당사자 또는 증인이 비디오 등 중계장치에 의한 신문을 요청하더라도 이는 법원의 직권 발동을 촉구하는 의미를 가질 뿐이다.

법원은 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하여 증인을 신문하기 위한 요건이 구비되었는지를 확인하기 위하여 필요한 경우 당사자 또는 증인에게 주민등록등본, 재직증명서 등의 자료를 제출하도록 요청할 수 있다.

비디오 등 중계장치에 의한 증인신문의 실시는 증인신문을 채택할 때에 함께 결정할 수 있고, 이미 채택된 증인을 신문하기 직전에 또는 신문의 진행 도중에 결정할 수도 있다.

비디오 등 중계장치에 의하여 증인신문을 실시할지 여부의 통지는 별도의 결정문 작성 없이 기일통지에 포함하여 통지함이 대체적인 실무이고, 기일 지정 전에 영상기일 신청에 대한 판단을 당사자에게 알려주어야 할 특별한 사정이 있는 경우에는 그러한 결정서(전산양식 A1820)를 작성하여 통지할 수 있다(영상재판예규 11조 1항).

다. 증인에 대한 출석요구 등

비디오 등 중계장치에 의한 증인신문을 실시하기로 결정한 경우 법원은 증인을 법정 아닌 곳으로서 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설이 설치된 곳에 출석하게 한다(민소규 95조의2, 73조의3 1항). 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설은 법원 청사 안에 설치하되, 필요한 경우 법원 청사 밖의 적당한 곳에 설치할 수 있다(73조의3 2항). 통상 증인의 거주지나 근무지와 가장 가까운 곳에 위치한 법원의 법정이나 영상신문실을 증인이 출석할 곳으로 지정하게 된다. 증인이 심리적인 부담으로 당사자 등과 대면하여 진술하기 곤란한 경우라면 수소법원의 다른 법정이나 영상신문실을 출석할 곳으로 지

정할 수 있다. 증인의 거동이 곤란하거나 수감되어 있는 등으로 필요한 경우에는 관공서나 그 밖의 공사단체 등에 설치하고 그곳으로 지정할 수도 있다(영상재판예규 27조 2항).

비디오 등 증계장치에 의한 증인신문이 결정되면 즉시 출석할 곳을 관할하는 법원의 영상재판담당자에게 연락하여 증인이 출석하여야 하는 정확한 장소의 정보를 확인한 다음, 증인에게 출석요구서와 영상신문 안내문[전산양식 A1823]을 송달하고, 출석할 곳을 관할하는 법원에 증인신문의 실시에 대한 협조를 요청하는 영상신문 촉탁서[전산양식 A1822]를 송부한다(영상재판예규 28조). 다만 수소법원의 다른 법정이나 영상신문실에서 신문이 실시되는 경우에는 촉탁서를 송부할 필요는 없다. 만일 증인이 편의성이나 사정변경 등을 이유로 출석할 곳의 변경을 요청하고 그 사유가 타당하다고 인정되는 때에는 법원이 출석할 곳을 새로 지정할 수 있으며, 촉탁서를 새로 송부하고 종전 장소에는 촉탁취소서를 보낸다.

촉탁서를 송부받은 법원의 영상재판담당자는 재판사무시스템에 입력하는 방식으로 영상재판 일정을 관리한다(영상재판예규 28조 3항). 출석법원 영상재판담당자는 비디오 등 증계장치를 설치하고 증인에 대한 문서제시의 방법 등에 관하여 수소법원과 미리 협의하는 등 증인신문을 준비하고, 증인신문 당일에는 선서서, 법원보관금 계좌입금신청서, 증인여비영수증 등의 서류를 준비하여야 한다. 여비 등에 관한 자세한 내용은 뒤의 9.를 참조.

관공서나 그 밖의 공사단체의 장에게 필요한 조치를 요구하는 경우에는 업무협조요청서[전산양식 A2538]를 송부하는 방식에 의한다(영상재판예규 29조 1항).

구치소, 교도소 등 수용시설이 출석장소로 지정된 경우, 재판장등은 증인이 편안한 분위기에서 영상재판에 참여할 수 있도록 수용시설의 장에게 필요한 조치를 요구할 수 있다(영상재판예규 29조 2항).

증인이 법정에 직접 출석하여 신문받기를 원하는 등의 사정으로 법원이

기일에 비디오 등 중계장치에 의한 증인신문 실시 결정을 취소하는 경우에는 그 취지를 조서에 기재하고, 이미 촉탁서를 송부하였다면 촉탁취소서를 송부하여야 한다.

[조서 기재례]

재판장

증인 ○○○에 대한 비디오 등 중계장치에 의한 증인신문 실시 결정을 취소한다는 결정 고지

라. 증인신문의 실시

비디오 등 중계장치에 의한 증인신문은 영상과 음향의 송수신에 의하여 법정 안의 법관, 당사자, 그 밖의 소송관계인과 법정 밖의 증인이 상대방을 인식할 수 있는 방법으로 한다(민소규 95조의2, 73조의3 1항). 영상재판담당자는 출석한 증인의 신분확인, 선서 등 절차에 필요한 조력을 제공하여야 한다.

재판장은 영상재판 시작 전 증인의 동의를 얻어 중계시설을 통하여 신분증을 제시하게 하거나 신분증을 녹화하는 방법으로 인적사항을 확인할 수 있다(영상재판예규 15조 1항). 증인의 주민등록번호 등이 노출되는 것을 방지할 필요가 있는 경우에는 재판장은 신분증의 주민등록번호 뒷자리를 가린 상태로 보여줄 것을 요청하거나, 재판장 컴퓨터를 제외한 스크린 및 당사자의 컴퓨터 화면을 끄는 방법 또는 재판장이 직접 신분증을 확인하지 않고 출석법원 영상재판담당자로 하여금 증인의 신분증을 확인하도록 하는 등의 간접적 방법을 이용할 수 있다(2항).

영상재판담당자는 증인이 기명날인 또는 서명한 선서서의 하단에 선서서 원본임을 확인한다는 취지를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 한다. 만일 증인이 선서서를 읽지 못하거나 기명날인 또는 서명하지 못하는 경우에는 영상재판담당자가 대독하거나 대서할 수 있다(민소 321조 3항, 영상재판예규 33조).

선 서

양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다.

증 인 ○ ○ ○ (인)

선서서 원본임을 확인함

법원서기 ○ ○ ○ (인)

증인에 대한 문서 등의 제시는 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설, 인터넷 화상장치 또는 ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙’ 2조 1호에 정한 전자소송시스템을 이용하거나 모사전송, 전자우편, 그 밖에 이에 준하는 방법으로 할 수 있다(민소규 95조의2, 73조의3 4항). 예를 들어, 제시하고자 하는 문서 등을 카메라로 촬영하여 비디오 등 중계장치를 통해 영상으로 보여주거나 팩시밀리를 통해 전송하는 방법, 전자기록사건의 경우에는 전자소송시스템을 통해(전자기록부어로 제시하여) 전자문서를 열람하게 하는 방법 등을 사용할 수 있다.

비디오 등 중계장치에 의한 증인신문은 증인이 법정에 출석하여 이루어진 증인신문과 동일한 법적 효력이 있다(민소 327조의2 2항). 비디오 등 중계장치에 의하여 증인을 신문한 때에는 법원사무관등은 그 취지와 증인이 출석하여 진술한 곳을 조서에 적어야 하고(민소규 95조의2, 73조의3 8항), 증인등 목록의 ‘비고’란에 증인이 출석한 장소, 사용된 비디오 등 중계장치 등을 기재한다(영상재판예규 별지 1 예시 라.).

[조서 기재례]

재판장

민사소송법 제327조의2에 의하여 ○○지방법원 제○호에 출석한 증인을 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통해 신문함을 고지
민사소송법 제159조 제1항의 규정에 따라 증인의 증언내용을 녹음할 것을 명하고 당사자에게 이를 고지, 별지 조서와 같이 증인 신문 증거관계 별지와 같음(원고 증인등)

[증인등목록 기재례]

20 가 ○ ○ 법 원 증 인 등 목 록					
원고 신청			변론(준비기일)조서의 일부		
기일 및 장수	증 거 방 법	증거 결정		증 거 조 사	비 고
		기 일	채 부		
1차	증인 ○○○	1차	㉠ 부	20○○. 4. 28. 14:00 (식시)	○○지방법원 제○호의 비디 오 등 중계장치 에 의한 중계시 설을 통해 신문
장					

제26장

증인

비디오 등 중계장치에 의한 증인신문에 대하여도 특별한 사유가 없는 한 원칙적으로 녹음이 필요한 경우에 해당한다고 보아 그 전부를 녹음하여 조서의 일부로 삼는다(민소 159조 1항, 2항, 속기·녹음예규 9조의2).

마. 증인신문 관련 서류의 송부

비디오 등 중계장치에 의한 증인신문이 끝난 후 출석법원 영상재판담당자는 증인신문에서 작성된 선서서 원본 등 서류를 영상신문 관련서류 송부서[전산양식 A1824]에 첨부하여 수소법원에 송부한다. 재판장등의 허가를 얻어 영수증, 선서서 등 서류에 대하여 증인이 전자패드에 서명하게 하는 방법으로 서류송부를 갈음하거나 서류에 자필서명을 받아 전자문서로 변환하여 수소법원에 전송할 수 있다(영상재판예규 34조 2, 3항).

영상재판담당자는 증인에게 제시하기 위하여 전자우편이나 팩시밀리를 통해 전송받은 문서는 신문 종료 즉시 폐기하면 되고, 해당 전자우편도 삭제하면 된다.

4. 인터넷 화상장치에 의한 증인신문

가. 의 의

법원은 멀리 떨어진 곳 또는 교통이 불편한 곳에 살고 있거나 그 밖의 사정으로 말미암아 법정에 직접 출석하기 어려운 사람 또는 나이, 심신상태, 당사자나 법정대리인과의 관계, 신문사항의 내용, 그 밖의 사정으로 말미암아 법정에서 당사자 등과 대면하여 진술하면 심리적인 부담으로 정신의 평온을 현저하게 잃을 우려가 있는 사람을 증인으로 신문하는 경우 알맞다고 인정하는 때에는 당사자의 의견을 들어 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하여 신문할 수 있도록 민사소송법이 2016년 개정되었음은 앞서 3.에서 설명한 바와 같은바, 이러한 경우에 인터넷 화상장치도 이용하여 신문할 수 있도록 2021년 민사소송법이 개정되었다(민소 327조의2 1항).

의견청취와 결정, 증인에 대한 출석요구, 증인신문 실시와 조서 기재례 등은 앞의 '3. 비디오 등 중계장치에 의한 증인신문'에서 설명한 바와 대부분이 비슷하므로, 여기에서는 차이가 있는 사항을 위주로 설명한다.

나. 의견청취 및 결정 등

인터넷 화상장치를 이용하는 절차에서는 증인이 자신의 집, 사무실 등에서 증인이 구비한 스마트폰, 컴퓨터 또는 태블릿 등의 기기를 이용하여 접속함으로써 증인신문에 임할 수 있으므로 시간과 장소의 제약으로부터 좀 더 자유로울 수 있다. 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 이용하는 절차에서는 증인이 그 중계시설이 설치된 장소(예컨대 인근 법원 청사 등)에 찾아가서 일정한 시간 동안 그곳에 머물러야 하는 것과 대조된다.

인터넷 화상장치를 통한 증인신문이 사안의 특수성에 비추어 적합한 경우가 있을 수 있다. 예컨대, 증인으로 하여금 사건 현장에 가서 증언하게 하면 증인이 그곳에서 보다 생생하고 정확하게 진술할 사안이 있을 수 있다. 또한, 의사를 비롯한 전문가 증인이 자신의 근무지 등 편한 곳에서 인터넷 화



상장치를 통하여 진술하게 하면, 출석에 관한 증인의 부담이 크게 줄어들고 익숙한 환경에서 기억을 환기하여 더 정확하게 진술할 것이 기대된다.

증인 신분의 확인, 진술의 신빙성 확보, 부당한 영향력 배제, 진술 왜곡 위험의 방지 등에 대해서도 고려하여 실시 여부를 결정해야 한다. 그리고 만약 영상재판의 두 가지 방식 중에서 인터넷 화상장치를 이용한 방식으로 하는 것이 부적절해 보이는 사건이라면, 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 이용하는 방식이 적절한지 고려해야 할 것이다.

영상재판 방식으로 증인신문을 실시하려 한다면 소송관계인의 의견과 여러 사정을 살펴서 두 가지 방식 중 적절하게 선택한다. 증인의 의견을 들어 볼 수도 있을 것이다(영상재판예규 10조 2항). 법원이 당사자·증인의 의견에 구속되는 것은 아니며 직권으로 결정하는 것임은 앞서 설명한 중계시설의 경우와 같다.

외국에 소재하는 사람을 증인신문하려는 경우에는 국제 영상재판에 대한 해당국의 방침 등 추가적인 고려사항이 있을 수 있으므로, 법원행정처의 협조·지원을 받을 수 있다(영상재판예규 6조의2).

다. 증인신문의 실시

인터넷 화상장치를 이용한 증인신문기일을 증인에게 통지하는 출석요구서에는 영상재판을 위해 지정된 인터넷주소를 적는다(영상재판예규 16조).

인터넷 화상장치를 이용하는 경우 증인이 영상기일에 지정된 인터넷주소에 접속하지 아니한 때에는 불출석한 것으로 보는데 다만, 책임질 수 없는 사유로 접속할 수 없었던 때에는 그러하지 아니하다(민소규 95조의2, 73조의3 5항). 만약 불출석으로 간주되면 증인은 불출석에 따르는 제재를 받게 될 수 있으므로, 접속 장애가 없도록 사전에 준비해야 하고, 장비 불량, 기기 설정오류 등에 대비해야 한다.

수소법원 법원사무관 등은 영상재판 도중의 장애 발생 등을 대비하여 사

전에 증인의 연락처를 확보하여야 하며, 필요한 경우 증인과 협의하여 기일 당일의 연락 및 문서제시 방법을 협의하고 이에 필요한 기기를 구비하여야 한다(영상재판예규 17조 1, 2항). 기일 지연 등으로 인하여 필요한 경우 증인에게 적절한 방법으로 예상 대기시간을 안내할 수 있다(3항).

인터넷 화상장치로 신문하는 증인이 선서할 때는 선서자의 얼굴이 화면에 나오도록 유의하여야 한다(영상재판예규 20조 1항). 선서서를 읽지 못하거나 기명날인 또는 서명하지 못하는 경우에는 수소법원 법원사무관 등이 이를 대신한다(민소 321조 3항, 영상재판예규 20조 2항).

선서서 등과 같이 증인이 작성해야 하는 서류가 있는 경우 전자우편으로 양식을 전송하거나 그 양식이 대한민국 법원 홈페이지에 게시되어 있음을 안내할 수 있다(영상재판예규 21조 1항). 증인으로 하여금 위 서류를 전자제출하도록 안내하되, 부득이 발생한 서류 송부비용은 일당이나 감정료 등과 함께 지급한다(2항).

인터넷 화상장치를 이용하여 출석한 증인에게는 원칙적으로 여비는 제외하고 일당만 지급한다(영상재판예규 22조).

통신불량, 소음, 문서 등 확인의 불편, 제3자 관여 우려 등의 사유로 영상 신문의 실시가 적당하지 아니한 경우 재판장등 또는 법원은 기일을 연기 또는 속행하면서 증인이 법정에 직접 출석하는 기일을 지정할 수 있다(민소규 95조의2, 73조의3 6항).

5. 격리신문과 재정신문

민사소송법 328조는 같은 기일에 두 사람 이상의 증인을 신문하는 경우에는 나중에 신문할 증인을 법정에서 나가도록 하는 것을 원칙으로 하면서(격리신문), 다만 필요하다고 인정하는 때에는 신문할 증인을 법정 안에 머무르게 할 수 있다(재정신문)고 규정하고 있다.

위 조항은 증인이 먼저 증언한 증인의 증언에 의하여 영향을 받는 것을

방지하기 위한 것이다. 그런데 전부 또는 일부 증인을 재정시킨 상태에서 신문하는 것이 ① 허위의 진술 또는 부정확한 진술을 방지하고 증인의 기억을 환기하는 데 도움이 되고, ② 다른 증인 간의 진술의 차이를 부각시키기 용이하며, ③ 도입적 신문이나 중복적 신문을 생략하는 데에도 도움이 되는 등의 장점도 있으므로, 필요하다고 인정하는 때에는 전부 또는 일부 증인을 재정시킨 상태에서 신문하는 방식도 활용한다[사건관리예규 14. 다. (2)]. 여러 증인을 동시에 퇴정시킬 경우, 그 증인들이 신문을 기다리는 동안 서로 담합하여 증언내용을 상의하거나 먼저 신문을 마치고 나온 증인에게 증언 상황을 물어보는 등으로 격리신문의 효과를 거둘 수 없는 사정이 예상된다면, 퇴정 전에 증인들에게 담합금지를 경고하거나 증인들을 법정 밖에서 서로 격리하는 등으로 적절한 조치를 취할 필요가 있다.

신문을 마친 증인도 부득이한 사정이 없는 한 그 기일이 끝날 때까지 법정에 대기하도록 조치하여, 뒤의 증언 또는 당사자신문결과와 모순되는 경우에는 재신문이나 대질 등의 방법으로 확인할 수 있도록 하는 것이 타당하다[사건관리예규 14. 다. (4)].

증인이 증언하는 과정에서 법정 안에 있는 특정인 앞에서는 충분히 진술하기 어려운 현저한 사유가 있을 때에는 재판장은 당사자의 의견을 들어 그 증인이 진술하는 동안 그 사람을 퇴정시킬 수 있다(민소규 98조). 증인이 증언할 때 특정인이 법정 안에서 야유나 욕설 등 법정질서를 해치는 행위를 하거나 그럴 우려가 있는 경우에는 재판장이 법정질서에 관한 권한을 발동하여 그 사람의 퇴정 등을 명할 수 있고(법조 58조 2항), 위와 같은 명백한 위반행위를 하거나 그러한 우려가 있는 경우가 아니더라도, 특정인이 법정 안에 있는 사실 자체에 의하여 증인이 위압되어 충분한 진술을 할 수 없는 경우에도 그 사람의 퇴정을 명할 수 있다.

6. 대질신문

가. 대질신문의 중요성

재판장은 필요하다고 인정한 때에는 증인 서로의 대질을 명할 수 있다(민소 329조). 증인 서로의 대질뿐 아니라, 필요한 때에는 당사자와 증인의 대질도 활용할 필요가 있다(368조).

과거 실무에서는 그 활용이 매우 저조하였으나, 최근 들어 중요성이 강조되고 있다. 원칙적으로 모든 증인·당사자를 한 기일에 신문하는 집중증거조사방식에서는 절차지연 등의 부작용 없이 대질신문의 본래 효과를 기대할 수 있다. 대질신문을 통하여 증인 상호 간 또는 증인과 당사자 사이의 진술의 차이점을 명확하게 부각하고 보다 현장감 있는 생생한 진술을 얻음으로써 사안의 진상을 파악하는 데에 많은 도움을 얻을 수 있으므로, 증인 상호 간 또는 증인과 당사자 본인 사이의 대질신문을 적절히 활용한다[사건관리예규 14. 다. (3)].

나. 운영상의 유의점

대질신문의 구체적인 방법으로는 ① 동시에 동일한 질문을 하여 각 증인에게 대답을 시키는 방법, ② 질문을 한 후 증인끼리 자유롭게 문답을 하게끔 시키는 방법, ③ 다른 증인의 진술을 들려주고 변명이나 반론을 시키는 방법, ④ 증인 상호 간에 질문을 시키는 방법 등이 있다.

대질신문은 증인·당사자 상호 간에 강한 대립감정을 품게 하여, 자기의 진술을 고집하고 상대를 강하게 비난하거나 공격하는 사례가 생길 수 있으므로, 적절한 소송지휘를 함으로써 정확한 문답이 이루어지도록 하는 것이 중요하다. 이러한 과정에서 드러나는 각 증인·당사자의 태도·성향까지 살필 수 있어 진술의 신빙성 판단에 유익한 경우도 있을 수 있는데, 법원이 이러한 증인·당사자의 태도 등까지 주시·관찰하고 있다는 점도 당사자나 증인에게 알게끔 설명하면 위와 같은 사태를 효과적으로 억제할 수 있는 경우

가 많을 것이다.

대질신문의 경우 진술의 진실성 유무와 무관하게, 사람들 앞에서의 토론 경험의 유무 등 진술능력이나 말솜씨의 차이가 부각되거나 상대의 기세에 눌려 충분히 진술하지 못하는 경우도 있을 수 있는데, 이러한 상황을 정확하게 파악하고 대처하기 위한 노력이 요구된다.

다. 조서의 기재방법

재판장이 증인 상호 간의 대질을 명한 경우에는, 재판장의 대질명령과 대질신문의 내용도 기재한다. 당사자는 대질신문을 요구할 권리가 없으므로 당사자가 대질신문을 신청한 경우에도 그 신청을 기재할 필요는 없다.

대질신문을 한 경우에 조서의 기재방법으로는, 일단 증인별로 따로 신문조서를 작성하면서 그중 실제로 대질이 행하여진 부분만을 어느 한 증인신문조서에 몰아서 기재하고 각 증인신문조서에 그 취지를 기재하는 방법이 주로 사용되고 있으나, 경우에 따라서는 하나의 조서에 대질자 전원의 인적사항을 기재하고 전원의 선서서를 첨부하며 대질명령을 기재한 다음 대질신문의 내용을 기재하는 방식도 사용할 수 있을 것이다.

[조서 기재례]

① 증인별로 따로 신문조서를 작성하는 경우

재판장

증인 ○○○와 앞서 신문한 증인 ◇◇◇을 대질시키다.

증인 ◇◇◇에게 앞에서 선서한 선서의 효력이 유지됨을 알려주었다.

증인들에 대한 신문내용은 법정녹음시스템의 녹음파일(고유번호: 0000)과 같다.

② 하나의 조서에 전부 기재하는 경우

재판장

증인○○○와 증인 ◇◇◇와의 대질을 명하였다.

증인들에 대한 신문내용은 법정녹음시스템의 녹음파일(고유번호: 0000)과 같다.

7. 대동증인·재정증인의 처리

증인을 신청한 당사자나 대리인이 여비납부 등 절차를 밟지 아니하고 증인을 대동하는 방식은 원칙적으로 허용하지 아니하여야 한다. 증인 명의의 여비포기서가 제출된다면 증인신문을 허용하여도 무방하나, 이 경우에도 신청인의 증인대동 의사 유무와 상관없이 법원은 증인에 대한 출석요구절차를 정식으로 실시하는 것이 바람직하다.

당사자 본인소송의 경우 증인과 증명할 사실의 관계가 명확하거나 다른 증인과 일괄하여 신문할 필요가 있는 경우, 간략한 사항을 확인할 증인이 불출석하게 되어 이에 대한 대체 증인을 급히 확보하여 출석시킨 경우 등에는 재정증인이라도 신문이 필요한 경우가 불가피하게 발생할 수 있다. 이때에는 먼저 상대방에게 이의 여부를 물어 이의가 없다면 신문을 허용하여도 무방하나, 이의가 있는 때에는 원칙적으로 신문을 허용하지 아니함이 타당하다.

8. 증인신문절차에서 당사자의 이의신청

재판장은 증인신문의 순서를 바꿀 권한이 있고(민소 327조 4항), 중복신문이나 유도신문·탄핵신문의 허용범위(민소 327조 5항, 민소규 91조 2항, 95조 2항)를 벗어나는 신문에 대하여는 이를 제한할 수 있다. 이러한 증인신문에 관한 재판장의 명령 또는 조치에 대하여 당사자는 바로 이유를 구체적으로 밝혀 이의할 수 있고(민소규 97조 1항), 이러한 당사자의 이의에 대해서는 법원은 바로 결정으로 재판하여야 한다(2항). 이러한 법원의 결정은 소송지휘에 관한 재판으로서 불복이 허용되지 아니하며 다시 이의가 있더라도 종국 판결에 대한 상소로써만 다룰 수 있을 뿐이다.

한편, 실무상 증인신문과정에서 당사자가 상대방의 신문에 대하여 이의를 하는 경우가 있는데, 이러한 이의는 '상대방의 신문에 대한' 재판장의 제한조치(직권발동)를 요청하는 것으로서 민사소송법 327조 5항, 민사소송규칙 95조 2항에 근거한 것이므로 위와 같은 '재판장의 명령 또는 조치에 대한' 이

의와는 성질이 다르다. 이러한 이의에 대하여 재판장은 적절한 명령·조치를 하거나 또는 그러지 않는다는 답변 등을 할 것이다.

이의신청과 그 재판에 관한 사항은 조서에 기재하여야 하는데, 그 구체적인 방법은 이의의 시기 및 대상과 내용에 따라 달라질 것이다. 즉 조서의 일부가 되는 녹음을 실시하기 전에 특정 신문사항을 둘러싸고 재판장의 신문제한에 대하여 불복하거나 재판장이 증인신문의 순서를 바꾸는 등의 조치에 불복하는 경우에는 변론조서에 기재하는 방법이 일반적일 것이다. 녹음이 실시되는 때에는 조서의 일부가 되는 녹음물에 이의신청과 그 재판에 관한 사항이 기록되므로 별도로 변론조서나 증인신문조서에 이를 기재할 필요가 없으나, 재판장이 적도록 명하거나 당사자의 청구에 따라 적는 것을 허락한 때에는 증인신문조서에 그 취지를 기재한다(민소 154조 4호).

위와 같은 이의절차는 단독판사가 심리하는 사건에도 적용되고, 이의에 대한 결정은 그 단독판사 자신이 하게 된다.

9. 여비·숙박료의 지급

증인에게는 민사소송비용법에 따라 여비·일당·숙박료를 지급하여야 하는데, 그 산출방식 및 지급절차에 관하여는 증인의 일당·여비 등의 지급에 관한 예규가 제정되어 있다. 자세한 내용은 제13장(소송비용) 참조.

법원이 요구하여 출석한 증인에게 책임 없는 사유로 증인신문을 하지 아니한 경우에도 여비 등은 지급하여야 한다. 이와 관련하여, '같은 증인에 대하여 다음 기일에 반대신문을 하는 경우의 예납의무자를 누구로 할 것인가?'라는 문제가 있는데, 주신문의 시행만으로 증인신문절차가 끝나는 것이 아니고, 상대방의 증인에 대한 반대신문권이 법상 보장되어 있으므로 주신문을 신청한 당사자가 반대신문을 위한 증인여비까지 예납하여야 한다(재판예규 275-2 '같은 증인에 대하여 다음 기일에 반대신문을 하는 경우의 조서작성 및 증인여비 예납 문제').

비디오 등 증계장치 또는 인터넷 화상장치에 의한 신문절차에서의 증인여비 등은 대법원 예규로 정하는 바에 따라 현금으로 지급할 수 있다(보관금규 13조의2).

인터넷 화상장치를 이용하여 출석한 증인에 대하여는 원칙적으로 여비는 제외하고 일당만 지급한다(영상재판예규 22조).

비디오 등 증계장치에 의한 증계시설에 출석한 증인에게 줄 여비 등은 출석장소를 기준으로 금액을 계산하며, 계좌입금 방식의 지급이 원칙이지만 법원 청사 안의 증계시설을 통하는 경우로서 부득이 현금 지급이 필요한 때에는 '법원보관금취급규칙의 시행에 따른 업무처리지침' 17조의2를 따른다(영상재판예규 35조).

10. 수명법관 또는 수탁판사에 의한 증인신문

가. 개 설

증인이 정당한 사유로 수소법원에 출석하지 못하는 때, 증인이 수소법원에 출석하려면 지나치게 많은 비용 또는 시간을 필요로 하는 때, 그 밖에 상당한 이유가 있는 경우로서 당사자가 이의를 하지 아니하는 때에는 법원은 수명법관 또는 수탁판사로 하여금 증인을 신문하게 할 수 있다(민소 313조). 이는 법원 밖 증거조사에 관한 민사소송법 297조의 특칙이라고 보아야 할 것이므로, 위 요건을 갖춘 경우에 한하여 수명법관 또는 수탁판사에 의한 법원 밖 증인신문이 허용된다. 그리고 위 요건은 증인이 법원에 출석하지 못하는 경우에 관한 것이므로 법원 구내에서(예컨대 판사실) 출석한 증인에 대하여 수명법관에 의한 증인신문을 하는 것은 특별한 사정이 없는 이상 허용되지 않는다.

한편 수명법관 또는 수탁판사는 검증에 필요하다고 인정하는 때에는 감정을 명하거나 증인을 신문할 수 있으므로(민소 365조), 이 경우에는 위 요건이 없더라도 증인신문을 할 수 있다.

수명법관 또는 수탁판사가 증인신문을 하는 경우에는 법원과 재판장의 모든 직무를 행한다(민소 332조, 민소규 100조, 38조의9).

나. 수명법관에 의한 증인신문

수명법관으로 하여금 증인신문을 하게 한다는 수소법원의 결정이 있고 재판장에 의한 수명법관의 지정이 있어야 하는데, 이는 앞서 본 변론준비절차에 회부하는 결정과 재판장의 수명법관 지정이 행해지는 경우와 유사하다. 따라서 그 예에 따라 위의 재판을 변론준비기일에 말로 고지하거나(“재판장, 증인 ○○○에 대한 신문을 수명법관으로 하여금 하게 한다는 결정 고지, 판사 ○○○를 위 수명법관으로 지정”이라고 기재), 독립된 서면으로 작성하여 고지하면 된다.

증인신문기일은 수명법관이 지정하여야 하고(민소 165조 1항 단서), 이후의 모든 절차 역시 수명법관이 법원과 재판장의 직무를 행하면서 주재하여야 한다. 수명법관에 의하여 수소법원 외에서 증인을 신문하거나 현장검증 및 문서소재장소에서의 서증조사(민소규 112조)를 할 경우에는 공개심리의 원칙이 반드시 적용되는 것은 아니다(대법원 1971. 6. 30. 선고 71다1027 판결).

수명법관에 의한 증인신문이 종료한 때에는 증인신문조서를 작성하여야 하는데, 이는 변론조서의 일부가 아니므로 그 앞에 통칭 기일조서[전산양식 A1662]라고 하는 예비용 양식의 조서를 작성하여 이를 기본조서로 삼아야 한다. 따라서 증인신문조서 중 ‘(○차 변론조서의 일부)’는 삭제하고, 위 기본조서에서도 ‘고지된 다음 기일’란은 삭제하고 법관의 직명은 “수명법관 판사”로 표시하며 본문란에는 “별지 조서와 같이 증인신문”이라고 기재하여야 한다.

다. 수탁판사에 의한 증인신문

증인신문의 촉탁은 증인채택의 증거결정이 있는 후 수탁판사에 의한 증인신문을 하기로 하는 법원의 결정[이 결정 역시 변론(준비)기일에 조서에 기재하여야 할 수도 있고 기일 외에서 결정서에 의하여 할 수도 있는데, 후자의 경우의 주문은

“증인 ○○○에 대한 신문을 ○○지방법원 판사에게 촉탁한다.”로 기재한다에 의하여, 재판장이 이를 한다.

촉탁하는 경우에는 촉탁받을 지방법원만을 지정하여 촉탁할 것이지(고등법원이 촉탁법원인 때에도 지방법원에 촉탁하여야 한다) 그 법원의 특정 법관을 지정하여 촉탁하여서는 안 된다. 촉탁법원은 증거조사촉탁서[전산양식 A1735]의 원본을 수탁법원으로 송부하고 부분은 기록에 편철하여야 하며, 촉탁서에는 당사자의 주소를 명기하여 수탁법원에서 당사자에게 출석요구서를 발송할 때 편리하도록 해주어야 한다. 촉탁서를 송부할 경우에는 증거조사에 필요한 비용(우표·여비·일당 등), 증인신문사항 4통(상대방이 2인 이상일 때에는 그 수에 3을 더한 통수)을 함께 송부하여야 한다.

수탁법원에서는 촉탁받은 사건을 공조사건으로 전산입력하고 민사공조기록표지[전산양식 A1014]를 사용하여 사건기록을 만들어야 한다. 사건명은 ‘증거조사촉탁’으로 기재한다. 촉탁법원으로부터 증거조사에 필요한 비용이 송부되어 오지 아니한 경우에는 수탁판사가 당사자에게 필요한 비용의 예납을 명하여 예납을 받은 후에 증인신문을 행하여야 한다.

수탁판사가 증인신문을 완료하였거나 수소법원(촉탁법원)이 증거결정을 취소하여 그 증인을 신문할 필요가 없어진 경우에는 그 증거조사에 관한 기록(민사공조사건기록)을 바로 수소법원에 보내야 한다(민소 298조). 송부할 기록은 증인신문조서뿐만 아니라 수소법원으로부터 받은 촉탁서, 증거조사기일에 당사자에게 보낸 출석통지서의 송달현황목록, 증인이 출석하지 아니하여 증인을 신문하지 아니한 기일조서 등 일체의 서류를 송부서와 함께 송부하여야 한다. 또 수소법원으로부터 증거조사비용을 송부받았거나 당사자로부터 그 비용을 예납받은 것이 있으면 그 수지(收支)를 밝히고, 잔액이 있으면 이를 함께 송부하여야 한다. 나중에 소송이 종결되었을 때 소송비용액확정 결정에 필요하기 때문이다. 수탁법원으로서 언제 어느 법원으로부터 어떤 증거조사에 대한 촉탁을 받고 어떻게 처리하였는가를 장부상 분명하게 해

두면 족하고 증거조사기록의 등본을 작성·보존할 필요는 없다.

수탁판사가 촉탁법원에 기록을 송부할 때에는 소정의 촉탁 증거조사 회답서[전산양식 A1875]에 의한다. 촉탁법원은 송부받은 위 기록(수탁법원의 민사 공조사건기록)을 기본소송기록에 첨철하여 둔다.

제26장

증인

라. 전촉(轉囑)에 의한 증인신문 촉탁

수탁판사는 필요하다고 인정할 때에는 다른 지방법원 판사에게 증거조사를 다시 촉탁할 수 있다. 이 경우 그 사유를 수소법원과 당사자에게 통지하여야 한다(민소 297조 2항). 전촉을 할 경우에는 중국사유(○○법원에 전촉) 및 일자를 입력하고, 해당 민사공조사건기록 전부(촉탁법원에서 송부되었거나 수탁법원에서 작성된 모든 서류가 가철된 것)와 비용 잔액을 첨부하여 송부해야 한다.

이 경우 전촉서[전산양식 A1737] 및 전촉통지서[전산양식 A1738]를 사용한다.

11. 증인의 통역

증인이 우리말을 하지 못하거나 듣거나 말하는 데 장애가 있으면 통역인이 필요하다. 각급 법원은 매년 1월 말까지 각 관할지역의 사정 등에 따라 통역인을 지정할 필요가 많으리라고 예상되는 1개 또는 수개의 외국어 및 듣거나 말하는 데 모두 장애가 있는 사람의 수어에 관하여 2인 이상의 통역인 후보자를 미리 선정하여 통역인 후보자 명단을 작성하여야 하는데, 통역인 후보자를 선정할 때 대상자의 통역경력 등을 고려하여 선정하여야 하고, 선정된 통역인 후보자에 대하여 주기적으로 소송절차 전반에 관한 소양교육 및 전문법률용어의 통역에 관한 교육을 실시하여야 한다(통역·번역예규 16조, 17조). 참여사무관등은 통역인 후보자 명단에서 해당 사건에 적합한 통역인 후보자를 골라 재판장에게 보고하여 통역인이 지정될 수 있도록 한다(20조).

한편, 법원 간·지역 간 사법통역서비스의 편차해소 및 법정통역의 질 향상을 위하여 법원행정처의 조직으로 법정통역센터가 설치되었는데(통역·번

역예규 8조), 참여사무관 등은 재판장의 명을 받아 법정통역센터 통역인을 통역인으로 지정하는 경우 재판사무시스템을 통해 법정통역센터 통역인의 일정을 확인한 후 법정통역센터 담당자에게 전화, 전자우편, 모사전송, 휴대전화 문자전송 등 적당한 방법으로 통역인지정결정 가부 확정 요청을 하고(22조 1항 1호), 법정통역센터 담당자는 그러한 요청을 받은 후 법정통역센터 통역인의 통역이 가능한 경우 재판사무시스템에 해당 통역 일정을 확정 입력하고 전화, 전자우편, 모사전송, 휴대전화 문자전송 등 적당한 방법으로 참여사무관 등에게 통역인 지정이 가능함을 통지한다(2호). 법정통역센터 통역인은 영상재판 또는 출장 방식으로 통역을 실시한다(9조 1호).

통역인의 통역에 소요되는 비용은 증명하고자 하는 당사자가 예납하여야 한다(민소규 19조 1항 3호). 통역인에게 지급할 통역료의 산정방식에 관하여는 제13장(소송비용) 참조.

다만, 듣거나 말하는 데 장애가 있는 사람을 위한 수어통역·농통역의 비용에 관하여는 당사자의 예납을 요하지 아니하며 국고 부담이다(민소규 19조의2 2항, 수어통역예규 3조 4항, 11조).

증인신문의 통역에 대한 정확성 확보를 위한 재판과정의 녹음·영상녹화와 통역에 대한 이의 등은 통역·번역 및 외국인 사건 처리 예규를 참조하고, 수어통역·농통역의 영상녹화나 속기 실시간 현출 등은 수어통역 등에 관한 예규를 참조한다.

제6절 증인신문조서의 작성

1. 서 설

증인신문조서는 [전산양식 A1656]에 따라 작성하여야 한다. 변론기일의 증인신문조서는 기본조서인 변론조서[전산양식 A1651]에 첨부하고, 변론기일

외의 증인신문조서의 경우에는 이른바 기일조서[전산양식 A1662]를 작성하고 증인신문조서를 뒤에 첨부하여 간인함으로써 기일조서를 완성한다. 기본조서만 색지를 사용하고 증인신문조서는 색지를 사용하지 아니한다(조서예규 6조 참조).

이하 증인신문조서 작성에 관한 설명은 원칙적으로 감정인신문조서와 당사자신문조서의 작성에도 그대로 적용된다.

2. 형식적 기재사항

증인신문조서 양식 중 인쇄되어 있는 부분이 이에 해당한다.

가. 차수, 인적사항

변론기일에서의 증인신문인 때에는 그 차수를 기입하여 기본조서와의 연결관계를 표시하여야 하고[법원 밖 신문인 때에는 ‘(○차 변론조서의 일부)’를 삭제한다], 사건번호와 사건명 및 증인의 인적사항을 정확히 기입한다. 기일은 기본조서의 ‘기일’란의 일시와 일치하여야 한다.

나. 선 서

재판장이 선서를 시키고 증언한 경우에는 양식에 인쇄되어 있으므로 특별히 기재할 필요가 없다. 재판장이 선서를 시키지 아니하고 신문한 경우나(민소 325조), 다음에 신문할 증인의 재정 여부에 관한 소송지휘(328조) 내용은 [전산양식 A1657] 등을 참조하여 증인신문조서에 기재한다.

증인이 한번 선서를 행한 경우에는 예정된 신문을 끝내지 못하여 다음 기일에 속행하는 경우나 일단 신문을 종료하고 그 증인을 새로이 채택하여 신문하는 경우에도, 전후의 신문사항이 전혀 무관한 경우가 아닌 한, 다시 선서를 시킬 필요가 없다. 이 경우 조서 기재례는 다음과 같다.

재판장

제○차 변론기일에 행한 선서의 효력이 유지됨을 알려주었다.

다. 동일한 증인에 대한 신문을 속행하는 경우

예정된 신문을 끝내지 못하여 다음 기일에 속행하는 경우에는 첫 번 기일의 변론조서 맨 마지막에 다음과 같이 부기한다.

증인 ○○○에 대한 나머지 신문(반대신문)은 다음 기일에 시행하기로 하고 속행

한편, 다음 기일의 변론조서에는 “증인 별지조서와 같이 신문(반대신문) 속행”이라고 기재한다. 이 경우 증인신문조서 자체에는 특별한 기재를 할 필요가 없다.

라. 증언·선서거부

① 증언거부가 이유 있다고 인정한 경우

증인

……라는 사유로 증언을 거부

재판장

당사자를 심문한 후 민사소송법 제○조 제○호 규정에 해당함을 인정하고, 증언거부가 이유 있다는 결정 고지

이 경우 변론조서에는 “출석한 증인 별지조서와 같이 증언거부”라고 기재하고, 증인등목록의 ‘증거조사’란에 “20○○. ○. ○. 14:00 (증언거부)” 방식으로 기재한다.

② 증언거부·선서거부가 이유 없다고 인정한 경우

증인

……라는 사유로 증언(선서)을 거부

재판장

당사자를 심문한 후 증언(선서)거부가 이유 없다는 결정 고지

이상의 각 결정은 조서에 기재하는 대신에 별도의 서면을 작성하여 고지 하여도 무방하다.

마. 속기한 경우의 속기자

민사소송법 152조, 159조에 따라 증인신문을 속기하는 때에는 기본조서의 ‘형식적 기재사항’란 중 법원사무관등의 ‘성명’란 아래에 난을 설치하여 “속기자 ○○○ 출석”으로, 변론의 요지란에 “증인 ○○○에 대한 신문은 속기 한다는 결정 고지”라고 기재하고, “증인 ○○○에 대한 신문내용은 별첨(별지) 속기록과 같으므로 이를 조서의 일부로 삼는다.”라고 기재한다. 그리고 증인신문조서의 요지란에 아래와 같이 기재한 다음, 속기록은 증인신문조서에 첨부하고 간인한다.

- ① 속기록의 전부가 조서에 인용되었을 때
증인의 진술은 별지 속기자 ○○○ 작성의 속기록과 같다.
- ② 속기록의 일부가 조서에 인용되었을 때
속기자 ○○○ 작성의 속기록 중 제○면 제○행부터 제○면 제○행까지의 기재와 같다.

위 민사소송법 규정에 따라 증인신문을 녹음하는 때에는 기본조서 중 변론의 요지란에 “민사소송법 제159조 제1항의 규정에 따라 증인의 증언내용을 녹음할 것을 명하고 당사자에게 이를 고지, 별지 조서와 같이 증인신문”으로 기재하고, 증인신문조서의 진술요지란에는 “증인 ○○○에 대한 신문내용은 법정녹음시스템의 녹음파일(고유번호: ○○○○○○○)과 같다.”라고 기재한다. 이때 속기자가 사후에 녹취서를 작성하기 위하여 참찰할 수 있으나, 이러한 경우에는 기본조서의 ‘형식적 기재사항’란에 속기자의 출석을 표시하지 않는다.

3. 실질적 기재사항

가. 기재요령

증인신문을 녹음 또는 속기하지 아니한 경우에 법원사무관등은 시각(증인의 동작)과 청각으로서 인식한 증인의 진술내용을 기재한다. 조서를 요령 있게 작성하기 위하여는 해당 사건의 쟁점을 파악하여 그 증인으로부터 어떤 사실을 증명하려고 하는가를 미리 알고 있어야 한다.

어떤 법률행위의 유무가 문제로 된 경우에는 그 유무를, 그 법률행위의 내용이 문제로 된 경우에는 그 법률행위에 관한 당사자의 의사표시 내용을, 물건의 상태가 문제로 된 경우에는 그 상태를 각기 정확하게 기재하여야 한다.

나. 진술의 요지

(1) 신문자의 표시

당사자가 신문할 경우는 “원고”, “피고”로, 대리인인 경우에는 “원고 대리인”, “피고 대리인”으로, 재판장인 경우는 “재판장”으로, 재판장이 아닌 판사가 재판장에게 알리고 신문할 경우에는 “판사 ○○○”으로 기재한다.

(2) 번호의 부여

진술의 기재방법은 문답식과 요약식의 두 가지 방법이 있는데, 증언내용을 인용할 경우 편의를 위하여 문답식의 경우에는 매 질문마다, 요약식의 경우에는 매 항목마다 문항의 첫머리에 “1.”, “2.”, “3.”, “4.” 식으로 번호를 붙이는 것이 좋다.

다. 진술의 기재방법

(1) 원 칙

증언은 긍정증언, 부정증언, 직접체험사실의 증언, 전문증언, 단정적 증언, 추정적 증언 등의 다양한 형태로 진술되는 것이므로, 증언의 의미를 정확하게 표현하여야 한다.

(2) 기재방법

① 문답식 작성방법

문장의 첫머리에 ‘문’, ‘답’을 표시하여 기재하거나 질문부분을 대담부분보다 2글자 정도 나오게 하여 알아보기 쉽게 구분하여 기재하는 방법이다.

1. 문: 증인은 이 사건 매매계약을 언제 하였습니까?

답: 작년 봄 무렵에 한 것 같습니다.

② 요약식 작성방법

질문부분은 기재하지 아니하고 대담부분, 즉 증인의 증언부분만을 요약하여 하나의 문장으로 표현하는 방법이다. 이 기재방법에 의하더라도, 필요한 부분(증인이 신문에 답하지 않은 경우) 또는 중요한 부분(예컨대 반대신문으로 증언을 변경한 때)이거나 이의에 대한 재판을 기재한 부분은 문답식으로 기재하여 조서내용을 분명히 하는 것이 좋다.

1. 증인은 이 사건 매매계약을 작년 봄 무렵에 한 것 같다.

(3) 문서의 제시

증인신문 시에 증인에게 서증을 제시하여 질문하는 경우가 흔히 있다. 문서의 진정성립을 확인하거나, 문서의 의미 내용을 밝히거나 기억을 환기시키기 위하여 문서를 제시하는 것이다. 이때에는 그 항목의 기재 전에 “갑 제3호증(임대차계약서) 제시”라고 기재하거나 “1. 제시한 갑 제3호증은 ……” 등으로 기재한다.

(4) 신문의 제한 등

당사자의 신문이 중복된 때나 쟁점과 관계없는 때, 기타 필요한 사정이 있는 때에는 법원은 당사자의 신문을 제한할 수 있다.

재판장

신문사항 중 제○항은 유도신문이므로 제한함

재판장

신문사항 중 제○항은 본 소송과 관계없는 사항이므로 제한함

재판장의 주의 또는 권고에 따라 증인이 자발적으로 진술을 변경 또는 철회하였을 때에는 새로운 신문과 그에 대한 진술만을 기재하면 된다.

(5) 증인에게 손수 문자를 쓰게 할 것을 명한 때(민소 330조)

이러한 명령의 구체적 내용과 그에 대한 행위의 결과를 기재한다. 증인의 행위의무는 증언과 관련되고 부수적이며 지극히 간단한 것에 한하고, 그 내용이 복잡하고 증거조사의 필요성이 크면 독립된 증거방법에 의하는 것이 타당하다.

재판장

증인에게 ‘영수증 금 1,000만 원’이라고 볼펜으로 쓸 것을 명
증인

위 명령에 따라 별지와 같이 쓰다

수기를 한 별지를 이 조서의 끝에 첨부

(6) 서류에 의하여 진술을 하도록 허가한 때(민소 331조 단서, 민소규 96조)

재판장의 허가에 의하여 서류에 의하여 진술을 한 경우에는 허가가 있다는 것과 서류에 의하여 진술하였다는 것을 기재한다.

재판장

증인이 매월 결산보고서에 의하여 진술할 것을 허가
증인

(위 결산보고서를 보면서)

1. 이 사건 20○○년 6월의 거래금액은 1억 2,350만 원이다.

(7) 진술 일부의 비공개(법조 57조 1항 단서)

진술 일부를 비공개(공개금지)로 한 경우에는 기본조서의 형식적 기재사항

중 공개 여부의 기재란에 “일부 비공개”라고 기재하고, 또 진술의 요지란의 해당사항란 윗 칸에 “이하 공개금지 후 진술”이라고 기재하며, 공개금지결정 취소 후에도 진술이 계속될 경우에는 “이하 공개금지결정 취소 후 진술”이라고 기재한 후 다음 칸부터 계속 기재해 나간다.

(8) 증인이 신문에 답하지 않은 경우

신문사항의 답변란에 “묵묵부답”이라고 기재한다. 요약식으로 조서를 작성할 때에도 이 부분에서는 문답식으로 써야 한다.

피고대리인

문: 증인은인가요

답: 묵묵부답

제26장

증인

4. 증인신문조서의 첨부서면 및 날인

가. 첨부서면

- ① 선서서
- ② 쓰게 한 서면(민소 330조)
- ③ 서면, 사진 등 증인이 진술에 사용하고 제출한 것(민소 156조)
- ④ 속기록과 녹음물

변론의 전부나 일부를 속기하거나 녹취한 경우에는 그 속기록과 녹음물은 조서의 일부가 된다(민소 159조).

나. 간인 및 날인

참여사무관등은 증인신문조서의 각 장 사이, 증인신문조서와 기본조서 사이 및 증인신문조서와 그에 첨부된 서류 사이의 각 우측 상단에 간인한다.

증인신문조서의 끝에는 참여사무관등과 재판장이 기명날인한다.

제7절 증인에 대한 과태료재판

1. 부과 사유

증인에 대한 과태료는 ‘적법한 출석요구’를 받은 증인이 ‘정당한 사유 없이’ 출석하지 아니한 때에 부과할 수 있다(민소 311조 1항). 따라서 증인이 출석하지 아니한 때에 과태료를 부과하기 위해서는 우선 증인에 대한 적법한 출석요구절차가 선행되어야 하고, ‘적법한 출석요구’를 받은 증인만이 그 대상이 된다(대법원 2008. 3. 24. 자 2007마1492 결정).

‘적법한 출석요구절차’라 함은 증인에게 출석요구서를 송달하여 기일을 통지함을 의미하고(민소 167조 1항), 이러한 절차를 거치지 않은 소위 대동증인에 대해서는 과태료를 부과할 수 없다. 또한 출석요구서는 부득이한 사정이 없는 한 출석할 날보다 2일 전에 증인에게 송달되어야 하므로(민소규 81조 2항), 이러한 요건을 갖추지 못하였다면 특별한 사정이 없는 한 적법한 출석요구절차를 거쳤다고 인정되기 어려울 것이다. 기일의 간이통지 즉 전화·팩시밀리 등 간이한 방법을 이용하여 증인에게 출석요구를 한 경우에는 과태료 부과와 같은 법률상의 제재를 가할 수 없다(민소 167조 2항).

‘정당한 사유’란 법정에 나올 수 없을 정도의 질병, 관혼상제, 교통기관의 두절, 천재지변 등을 말하는 것으로 해석된다. 출석요구서를 받고도 그 내용을 확인하지 않았거나 기일에 출석해야 하는 사실을 잊어버린 경우와 같이 과실에 의해 불출석한 경우에는 정당한 사유로 인정되기 어렵다.

정당한 사유의 존재는 증인 자신이 소명할 책임이 있고, 증인이 출석요구를 받고 기일에 출석할 수 없을 경우에는 바로 그 사유를 명시하여 신고하여야 하므로(민소규 83조), 불출석 사유서를 제출하지 않은 증인에 대해서는 원칙적으로 과태료를 부과함이 타당하다. 다만 첫 기일에 출석하지 아니한 증인이 다음 기일에는 반드시 출석할 것임을 다짐하거나, 대리인 등을 통하

여 구두로 불출석 사유를 소명한 경우 등에는 일단 과태료 부과를 유보하였다가 향후의 태도에 따라 결정을 하는 방안도 활용할 수 있을 것이다. 불출석 사유서를 제출하였더라도 소명자료를 붙이지 않거나 정당한 사유로 인정되지 않는 때에는 불출석 사유서를 제출하지 아니한 경우에 준하여 처리하면 된다.

정당한 사유 없이 출석하지 않은 이상, 증인이 단 1회 불출석한 경우에도 과태료를 부과할 수 있으며, 반드시 2회 이상 불출석한 경우에만 부과할 수 있다거나 과태료 부과에 앞서 구인절차를 먼저 거쳐야만 하는 것은 아니다. 불출석할 때마다 과태료를 거듭 부과할 수 있으므로, 증인이 최초 기일에 불출석하여 과태료를 부과받았음에도 불구하고 재차 출석을 요구받은 기일에 또 출석하지 않은 경우에는 두 번째 불출석 행위에 대하여 별도의 과태료를 부과할 수 있음은 물론, 뒤에서 보는 바와 같이 감치에 처할 수도 있다.

증언의 거부가 이유 없다고 한 재판이 확정된 후 증인이 증언을 거부한 경우 및 증인이 선서를 거부한 경우에도 과태료를 부과한다(민소 318조, 326조).

과태료 부과와 아울러, 불출석으로 말미암은 소송비용을 부담하도록 명할 수도 있다(민소 311조 1항).

2. 관할법원

증인에 대한 과태료재판은 수소법원이 관할한다(민소규 85조 1항). 일반 과태료 사건의 경우에는 과태료에 처할 자의 주소지 지방법원이 관할하나(비송 247조, 질서위반행위규제법 25조), 민사소송규칙에 특칙을 둔 것이다.

증인에 대한 과태료재판은 본안재판에 부수하는 성격을 지니고 있는 만큼 실무상은 본안사건의 담당재판부가 처리하는 것이 일반적이고, 다만 과태료 결정에 대한 재항고 결과 대법원에서 원심결정을 파기환송한 경우에는 원심 결정에 관여한 판사는 환송 후의 재판에 관여할 수 없으므로(민소 443조 2항, 436조 3항), 환송 후의 과태료재판은 원래 결정을 한 재판부가 아닌 다른 재

판부가 하여야 한다.

3. 부과절차

가. 개 요

과태료의 부과절차에 관해서는 비송사건절차법 248조와 250조가 준용되므로(민소 224조 2항, 민소규 85조 2항), 증인에 대한 과태료 부과절차는 크게 약식절차와 정식절차로 나누어진다. 다만 비송사건절차법 248조 및 250조 중 검사에 관한 규정은 준용되지 않으므로(민소 224조 2항, 민소규 85조 2항), 결정에 앞서 검사의 의견을 들을 필요는 없으며, 나아가 검사는 증인에 대한 과태료재판에서 일방 당사자가 아니기 때문에 별도의 이의신청권이나 항고권이 인정되지 않는다. 이런 점에서 일반 과태료 사건과 차이가 있다.

나. 사건번호 및 사건명, 기록의 조제

증인에 대한 과태료 부과는 본안재판에 부수하는 재판으로서 신청에 의해 이루어지는 것이 아니라 직권으로 하는 것이고(대법원 1998. 4. 13. 자 98마 413 결정), 즉시항고가 되기 전에는 그 자체로 독립된 사건이 아니므로, 별도의 사건번호나 사건명을 부여하지 않고 본안사건의 사건번호와 사건명을 그대로 사용한다. 기록도 별도로 조제하지 않고 그 결정서나 이의신청서 등 관련서류는 모두 본안기록에 가철하여야 한다(인지액·편철방법예규 2조 1호).

다. 약식절차

(1) 약식결정

과태료재판은 미리 당사자의 진술을 듣고 하는 것이 원칙이지만(비송 248조 2항), 법원이 타당하다고 인정할 때에는 당사자의 진술을 듣지 않고 할 수 있는데(250조 1항), 이를 '약식절차'라 한다. 증인에 대한 과태료 사건은 위반 사실이 객관적으로 현저할 뿐만 아니라 증인 스스로 불출석 사유서를 통하

여 정당한 사유를 소명해야 하는 점, 출석요구에 불응한 증인에 대하여 다시 진술청취절차를 거치는 것은 절차지연의 우려가 있다는 점 등을 감안할 때, 원칙적으로 약식절차에 따라 재판을 함이 타당하다.

과태료재판은 이유를 붙인 결정으로 하여야 하고(비송 248조 1항), 약식절차에 의한 과태료결정의 양식은 [전산양식 A2500]과 같다. 집행기관인 검사는 과태료결정서에 의하여 대상자를 특정해야 하므로, 집행의 실효성을 위하여 위 결정문 양식대로 증인의 주민등록번호도 기재할 필요가 있다.

약식결정은 이를 받은 증인에게 고지함으로써 효력이 생긴다(비송 18조 1항). 일반 비송사건에서 결정의 고지는 법원이 적당하다고 인정하는 방법으로 하면 되나(2항), 증인에 대한 과태료 약식결정은 일정한 제재를 가하는 재판의 성질에 비추어 고지된 날을 명확히 할 필요가 있고 증인이 다른 방법으로 부과사유를 파악하기는 어려우므로 위와 같이 이유가 적힌 결정의 등본을 송달하는 방법으로 고지함이 타당하다(과태료예규 2.). 검사는 당사자가 아니고 이의신청권도 없기 때문에 확정되기 전에는 별도로 결정등본을 송부할 필요가 없다.

(2) 약식결정에 대한 이의신청

약식결정에 대하여 증인은 그 결정을 고지받은 날부터 1주 이내에 이의신청을 할 수 있다. 적법한 이의신청이 있으면 약식결정은 그 효력을 잃고, 법원은 정식절차에 따라 당사자의 진술을 듣고 다시 재판을 하여야 한다(비송 250조 2항 내지 4항).

약식결정에 대해서는 이의신청을 할 수 있을 뿐 곧바로 즉시항고를 제기할 수는 없으므로, 약식결정에 대하여 즉시항고장이 제출된 경우에는 이를 즉시항고 사건으로 보아 상급법원에 기록을 송부할 것이 아니라 이의신청으로 보아 정식절차를 진행하여야 하고 그 관할법원은 약식재판을 한 법원이 된다(대법원 2001. 5. 2. 자 2001마1733 결정, 과태료예규 3. 나.).

이의신청은 명문의 규정은 없으나 절차상 명확성을 기하기 위하여 서면으

로 하여야 할 것이다. 다만, 증인이 법정에 출석하여 말로 이의신청을 하면 이를 조서에 기재하는 실무례도 있다. 이의신청서에는 인지를 첨부할 필요가 없다(인지 10조 단서, 인지액·편철방법예규).

이의신청기간이 지나면 약식결정은 확정되어 더 이상 다룰 수 없게 된다. 따라서 그 후에 제기된 이의신청은 부적법한 신청으로서 각하해야 한다(대법원 1982. 7. 22. 자 82마337 결정). 이의신청 각하결정에 대해서는 비송사건절차법 248조 3항을 준용하여 즉시항고를 할 수 있다고 해석된다.

다만 증인이 책임질 수 없는 사유로 인하여 이의신청기간을 준수할 수 없었던 경우에는 민사소송법 173조 1항 본문을 준용하여 그 사유가 없어진 후 2주 이내에 이의신청을 추후보완할 수 있다(대법원 1981. 9. 30. 자 81마 280 결정 참조).

이의신청기간이 지나서 확정된 약식결정을 추완이의에 따른 절차를 거치지 아니하고는 법원이나 재판장이 임의로 취소·변경할 수 없다는 견해가 있어 주의를 요한다. 확정되어 기속력이 있고 소송지휘에 관한 결정·명령에 해당하지 아니함을 이유로 한다. 이미 확정된 약식결정에 대하여 출석한 증인이 이의를 한다면 그에게 물어서 추완이의 사유가 있는지 없는지를 심리할 것이다. 실제 출석하여 이의를 진술한 그 증인이 반드시 객관적인 증빙을 제출하지 않았더라도 증인의 진술 등에 기초하여 추완이의 사유를 인정하는 실무례도 있다.

이의신청의 취하에 관해서는 명문의 규정은 없지만, 즉시항고의 취하에 준하여 정식절차에 의한 결정이 있기 전까지는 취하할 수 있고, 이 경우 별도의 조치 없이 약식결정은 그대로 확정된다고 보는 것이 일반적인 견해이다.

라. 정식절차

(1) 개 관

정식절차는 당사자의 진술을 듣고, 검사의 의견을 구하는 절차를 거쳐 과

태료 결정을 하는 것을 말한다(비송 248조 2항). 증인에 대한 과태료재판의 경우 검사에 관한 규정은 적용되지 않기 때문에, 증인의 진술을 듣는 절차만 거치면 된다. 약식결정에 대하여 적법한 이의신청이 있으면 정식절차에 따라 다시 재판을 하여야 한다는 점은 전술한 바와 같다.

(2) 진술청취절차

진술은 서면 또는 구술로 할 수 있으므로(민소 161조 1항, 비송 8조), 증인의 진술을 듣는다고 하여 반드시 심문기일을 열 필요는 없으며, 증인으로 하여금 서면(의견제출요구[전산양식 A2501])으로 의견을 진술할 기회를 부여하면 족하다. 증인에게 진술할 기회를 부여한 이상, 증인이 의견서를 제출하지 않거나 심문기일에 출석하지 않은 경우에는 그대로 결정을 하더라도 무방하다.

(3) 정식결정

처음부터 정식절차로 진행한 경우의 결정문 양식은 약식절차에 의한 과태료결정과 동일하다. 그러나 약식결정에 대한 이의신청에 의하여 정식절차로 진행된 경우에는 그 결정문의 사건명 옆에 “(과태료결정에 대한 이의신청)”이라고 기재하고, 주문 상단에 약식결정일을 기재하여야 하는데(과태료예규 3. 가.), 구체적 양식은 [전산양식 A2502]와 같다.

정식절차로 심리한 결과 증인이 출석하지 않은 데 정당한 사유가 있었던 것으로 판명된 경우에는 불처벌결정을 하여야 하고, 이 경우 주문은 “증인을 벌하지 아니한다.”라고 기재하면 된다.

약식결정을 받은 증인이 다음 증인신문기일에 출석하여 증언했다고 하여 반드시 불처벌결정을 하여야 하는 것은 아니다(증인 감치재판의 경우는 감치결정 전에 증언하면 반드시 불처벌결정을 하여야 함). 다만, 과태료의 부과가 증인의 출석확보에 그 주된 목적이 있다고 볼 사안이고 재판기일의 공전과 시간 낭비 등의 피해가 크지는 않았다고 볼 경우라면, 이러한 증인에 대해서는 과태료의 액수를 감하여 주거나 불처벌결정을 할 수 있을 것이다. 소송당사자들의 의견도 들어 보고 참고할 수 있을 것이다.

약식결정에 대한 이의신청이 있는 경우 불이익변경금지의 원칙이 적용되는지가 문제 된다. 약식결정은 이의신청에 의하여 그 효력을 상실하므로 정식절차에서는 약식결정보다 무거운 과태료를 부과할 수 있다는 견해가 있지만, 이의신청 제도의 취지에 비추어 불이익변경금지의 원칙이 적용된다는 반대의 견해도 있다.

정식결정의 고지방법이나 검사에 대한 고지 여부 등은 약식결정의 경우와 같다.

4. 정식결정에 대한 항고

가. 즉시항고권자 등

증인은 정식결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있다(민소 311조 8항). 검사나 본안사건의 당사자는 과태료 사건에서는 당사자가 아니기 때문에 즉시항고권이 없다. 약식결정에 대하여 곧바로 즉시항고를 할 수 없음은 전술한 바와 같다.

이러한 즉시항고에는 민사소송법 447조의 적용이 배제되어 집행정지의 효력이 없다(민소 311조 8항 단서, 민소규 85조 2항).

즉시항고장에는 2,000원의 인지를 붙여야 한다(인지 11조 2항). 처음부터 정식절차로 진행되었는가, 아니면 약식결정에 대한 이의신청에 의해 정식절차로 회부되었는가에 상관없이 그 인지액은 같다.

나. 즉시항고기간

즉시항고기간은 재판의 고지일부터 1주이다(민소 444조 1항). 원심재판장의 항소장 심사권에 관한 민사소송법 399조가 준용되므로(443조 1항), 항고기간이 도과한 이후에 제기된 즉시항고는 원심재판장이 항고장각하명령을 하여야 하며, 이 각하명령에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다(402조 2항, 3항). 증인이 책임질 수 없는 사유로 즉시항고기간을 준수할 수 없었던 경우

에는 민사소송법 173조에 따라 추후보완할 수 있다.

원심법원은 즉시항고가 이유 있다고 인정하는 때에는 원결정을 경정하여야 한다(민소 446조).

제26장

증인

다. 항고기록의 조제·송부

(1) 기록의 조제

증인에 대한 과태료 사건은 기록을 별도로 만들지 않고, 그 결정서 등은 본안기록에 함께 붙이므로, 즉시항고가 제기된 경우 항고심으로 송부할 기록을 어떻게 만들어야 할 것이냐가 문제 된다.

이와 같은 경우에 본안기록 전부를 등본하여 송부하는 것은 비효율적일 뿐만 아니라 항고심에서 판단을 하는 데에 오히려 방해가 될 소지도 있다. 따라서 본안사건의 내용을 파악할 수 있는 최소한의 자료와 증인에 대한 출석요구절차 및 불출석 사실을 증명할 수 있는 자료, 과태료결정과 관련된 서류들만을 등본하여 기록을 조제·송부하는 방식으로 처리함이 타당하다.

구체적으로는, 본안기록 표지, 증인등목록, 소장 또는 판결서, 증인신청서, 해당 증인의 채택 사실이 표시된 변론조서, 여비예납서, 증인출석요구서의 송달현황목록, 해당 증인이 불출석한 사실이 표시된 변론조서 등의 등본과 과태료 결정문, 이의신청서, 의견제출요구서 및 증인이 제출한 의견서, 즉시항고장 등 결정과 관련한 서류의 원본 또는 등본을 편철하면 될 것이다.

등본을 할 문서의 범위에 관하여 의문이 있을 때에는 참여사무관등은 재판장과 협의하여 그 범위를 특정하여야 한다. 항고기록으로 송부하기 위하여 과태료 결정문 등의 원본을 발췌한 본안기록에는 그 등본을 작성하여 편철한다.

(2) 기록의 송부

기록을 송부할 때 재판부의 의견서를 첨부할 필요는 없다. 항고심에서 과태료결정이 확정되어 항고기록이 원심법원으로 반환된 경우 그 기록은 본안

기록에 침철함이 타당하다. 즉시항고 이후 본안사건이 항소심으로 넘어간 경우에는 항고법원은 확정된 과태료 사건의 기록을 본안기록이 있는 항소심 법원으로 반환하여야 한다.

라. 항고심의 처리

항고심에서의 처리는 일반적인 항고사건의 경우와 다를 바 없다. 사건부호는 민사항고사건에 대한 사건부호인 ‘라’로 붙인다. 다만 사건명은 1심 본안사건명이 아닌 ‘증인과태료’로 붙이는 것이 타당하다.

항고심에는 민사소송법 415조 본문이 준용되므로(민소 443조 1항), 불이익 변경금지의 원칙이 적용된다.

마. 재항고

항고법원, 고등법원 또는 지방법원 항소부의 결정에 대해서는 재항고를 할 수 있다(민소 442조). 고등법원과 지방법원 항소부의 결정은 항고법원으로서 한 결정이 아니라 항소법원으로서 최초로 한 결정이라 하더라도 재항고의 대상이 된다.

사건부호는 민사재항고사건에 대한 사건부호인 ‘마’로, 사건명은 항고심의 경우와 같이 ‘증인과태료’로 붙인다. 재항고 결과 파기환송된 경우 별도의 사건부호(‘라’)와 사건번호를 부여하여야 하고, 원래 결정을 한 재판부가 아닌 다른 재판부에서 처리하여야 한다.

5. 과태료결정 확정에 따른 사무

가. 검사에 대한 결정등본 송부

과태료의 재판은 검사의 명령으로 집행한다(민집 60조 1항, 비송 249조 1항).

따라서 약식결정이든 정식결정이든 과태료 부과결정이 확정된 때에는 부과 결정을 한 재판부의 참여사무관등은 그 결정등본을 대응 검찰청의 검사에게

송부하여야 한다(과태료예규 2.와 5. 참조). 과태료집행촉탁[전산양식 A2559]을 적절히 수정해서 표지로 삼는다. 불처벌결정은 집행을 요하지 아니하므로 송부할 필요가 없다.

과태료 부과결정이 항고심에서 확정된 경우에는 항고법원의 참여사무관등이 항고심 결정과 함께 원심결정 등본을 송부하여야 한다.

과태료결정이 확정되었는데도 검찰에 송부하지 않고 방치하는 일이 없도록 유의해야 한다.

집행의 실효성을 위하여는 과태료결정에 증인 주민등록번호 등의 인적사항이 정확히 기재되었는지 확인할 필요가 있다.

과태료재판의 확정일자(는) 검찰의 집행착수 및 과태료 소멸시효(5년)의 기준이 되므로, 검찰에 송부하는 결정등본의 우측 상단에 아래 양식에 따라 확정일자를 부기하여야 한다.

20〇〇. 〇. 〇. 확정	(인)
----------------	-----

나. 기록 보존

증인에 대한 과태료결정과 관련한 기록은 즉시항고가 제기되지 않는 한 별도로 만들지 아니하고 본안기록에 함께 붙이므로, 과태료결정이 확정되더라도 그 부분 기록만을 따로 떼어 기록 보존을 하지는 않는다. 즉 과태료 관련기록은 본안기록과 운명을 같이하는 셈이다. 항고심에서 과태료결정이 확정되어 원심법원에 반환된 항고기록을 본안기록에 첨부한 경우에도 보존은 주기록인 본안기록과 함께 하여야 한다(인지액·편철방법예규 2조 3호 첨부절정의 참조).

다만 사건기록과 보존기간을 달리하는 재판원본은 기록에서 발췌하여 별도로 보존하여야 하므로(보존예규 11조 1항), 과태료결정 원본은 기록에서 발

체하여 별도로 보존하여야 한다. 그러므로 결정원본을 별도로 보존하지 않거나, 심지어 원본 자체를 검찰에 송부하는 일부의 실무례는 잘못이다. 결정원본을 발췌한 본안기록 또는 항고기록에는 결정등본을 작성하여 편철한다. 증인에 대한 과태료결정 등 민사소송법에 의한 과태료재판 원본의 보존기간은 5년이다(재판사무규 별표 2).

제8절 증인에 대한 감치재판

1. 개 설

증인감치에 관한 기본적인 재판절차는 과태료재판과 함께 민사소송법 311조에 규정되어 있고, 세부적인 절차에 관해서는 민사소송규칙 86조 및 이 규칙에 의하여 준용되는 ‘법정등의질서유지를위한재판에관한규칙’이 적용된다.

감치재판을 과태료재판과 비교하면, 재판과정에서 법정사유가 발생하면 당사자의 신청에 관계없이 법원의 직권에 의해 절차가 개시되는 점, 절차가 개시되더라도 일정한 경우에는 불처벌결정을 할 수 있는 점에서 유사하다.

그러나 감치재판에 있어서는 신체구금으로 증인이 경제활동의 중단, 생활관계의 파괴 등으로 적지 않은 불이익을 입게 되므로 절차의 안정을 기하고 제재에 따른 불이익을 최소화하기 위하여 ① 감치사유가 발생한 날부터 20일이 지난 때에는 감치재판개시결정을 할 수 없도록 기한의 제한을 두고 있고(민소규 86조 2항), ② 감치재판의 기일을 지정하여 증인에게 출석요구를 하여야 하며(민소 311조 3항), ③ 증인이 감치집행 중에라도 증언을 하면 법원은 바로 감치결정을 취소하고 그 증인을 석방하도록 한 점(7항) 등에 특색이 있다.

2. 감치의 사유

가. 과태료재판의 확정

증인감치는 증인이 민사소송법 311조 1항의 규정에 따른 과태료의 재판을 받고도 정당한 사유 없이 다시 출석하지 아니한 때에 처할 수 있다(민소 311조 2항).

감치의 요건이 되는 과태료재판은 민사소송법 311조 1항의 규정에 따른 과태료재판, 즉 증인신문기일에 정당한 사유 없이 불출석한 경우의 과태료재판에 한정된다. 따라서 증언거부나 선서거부로 인하여 과태료재판을 받은 경우(민소 318조, 326조)는 이에 해당하지 않는다.

민사소송법 311조 2항에서 “과태료의 재판을 받고도”라고만 규정하고 있으므로 과태료의 재판이 있었으나 이의신청·즉시항고 등으로 아직 확정되지 않은 경우에 바로 감치재판을 할 수 있는지 여부에 관해서는 의문이 있을 수 있으나, 감치재판의 취지나 성격에 비추어 보면 여기의 “과태료의 재판을 받고도”는 과태료재판이 확정된 경우를 의미하는 것으로 해석함이 타당하다.

나. 정당한 사유 없는 불출석

감치는 과태료재판 이후에 열린 증인신문기일에 적법한 출석요구를 받고도 정당한 사유 없이 다시 출석하지 아니한 때에 처할 수 있다. 이 경우의 ‘적법한 출석요구’나 ‘정당한 사유 없는 불출석’은 과태료재판의 부과 사유와 동일하다.

과태료재판을 받고도 정당한 사유 없이 다시 출석하지 않은 이상, 증인이 과태료재판 후 단 1회 불출석한 경우에도 바로 감치재판을 개시할 수 있으며, 반드시 2회 이상 불출석한 경우에만 감치재판을 개시할 수 있다거나 감치재판개시결정에 앞서 구인절차를 먼저 거쳐야 할 필요도 없다.

3. 관할법원

증인에 대한 감치재판은 수소법원이 관할한다(민소규 86조 1항). 과태료재판과 마찬가지로 재판의 성격상 본안사건이 계속된 수소법원이 처리할 필요가 있고, 과태료재판이 선행될 것을 요건으로 하고 있으므로 그 관할을 일치시키는 것이 타당하기 때문이다.

감치결정에 대한 재항고 결과 파기환송된 경우 환송 후의 감치재판은 원래 결정을 한 재판부가 아닌 다른 재판부가 하여야 하는 점은 앞서 본 과태료재판의 경우와 같다.

4. 감치재판절차

가. 감치재판개시결정

감치재판절차는 법원의 감치재판개시결정에 따라 개시된다(민소규 86조 2항 전단). 감치사유가 발생한 경우 감치재판의 개시 여부는 법원의 재량이다. 따라서 당사자의 감치재판 신청은 법원의 직권발동을 촉구하는 의미를 가질 뿐이다.

감치재판의 개시 여부를 판단하는 데에는 증인의 불출석 사유, 그 증인의 필요성 정도, 향후 출석 전망 등이 고려될 수 있을 것이다.

감치재판개시결정의 시기도 원칙적으로 법원의 재량이지만, 감치사유가 발생한 날부터 20일이 지난 때에는 감치재판개시결정을 할 수 없다(민소규 86조 2항 후단). 감치사유가 발생한 날부터 20일이 지나기 전에 개시결정이 이루어지면 족하고 그때까지 증인에게 그 결정이 고지되어야 하는 것은 아니다.

감치재판개시결정은 증인이 없는 상태에서 하게 되므로, 위와 같은 기한의 준수 사실을 명백히 할 필요가 있다. 따라서 감치재판개시결정서(전산양식 A2510)를 따로 작성하여 증인에게 송달하여야 할 것인데, 이는 뒤에서 보는 바와 같이 감치재판기일의 기일통지서와 함께 송달하는 것이 바람직하다.

감치재판은 법원의 직권으로 개시되는 절차이므로 본안사건의 당사자에게는 감치재판개시결정서를 송달할 필요가 없다. 다만 뒤에서 보는 바와 같이 감치재판의 집행이 이루어지면 바로 증인신문기일을 열어야 하므로 그 준비를 위한 전제로서 당사자에게도 감치재판개시사실을 적당한 방법으로 통지하여 주는 것이 바람직하다.

감치재판개시결정에 대해서는 불복할 수 없다(민소규 86조 4항). 감치재판개시결정은 일종의 중간재판에 해당되며 그 절차 내에서 감치결정이 내려진 때에는 감치결정에 즉시항고로 불복할 수 있으므로(민소 311조 8항), 독립하여 불복하지 못하도록 한 것이다.

감치재판절차는 본안사건의 소송절차와는 별개의 절차이므로, 감치재판절차가 개시되었다고 하여 본안사건의 소송절차가 중단되지는 않는다. 따라서 감치재판절차의 진행과 관계없이 담당재판부는 본안사건의 기일을 지정하여 진행할 수 있다.

나. 감치재판기일

(1) 증인의 출석

법원이 감치재판개시결정을 한 경우에는 감치재판기일을 열고 증인을 출석하게 하여 증인신문기일에 출석하지 않은 데 정당한 사유가 있는지 여부를 심리하여야 한다(민소 311조 3항).

감치재판기일은 일반 재판기일과 상관없이 담당재판부의 사정에 따라 적당한 기일을 지정하면 된다. 다만 본안사건의 증인신문기일과 연계하여 감치재판기일을 증인신문기일과 같은 날로 지정(시간대는 감치재판기일을 뒤로 지정)함으로써 증인의 출석·증언을 유도하고 그 결과에 따라 감치재판의 진행방향을 결정하는 방안도 효율적인 기일운영이 될 수 있다.

감치재판기일의 통지는 증인에게 기일통지서를 송달하는 방법으로 한다. 감치재판기일이 본안사건의 증인신문기일과 같은 날로 지정되더라도 시간대가

다르고 절차적으로 별개의 기일이므로 증인신문기일의 출석요구서와 별도의 기일통지서를 동봉하여 송달하여야 한다.

감치재판기일은 원칙적으로 증인의 출석 없이는 열 수 없지만, 증인이 정당한 이유 없이 출석하지 아니하거나 재판장의 허가 없이 퇴정한 때 또는 재판장의 질서유지를 위한 퇴정명령을 받은 때에는 증인의 출석 없이도 기일을 열 수 있다(민소규 86조 6항, 법정질서규 6조 1항).

따라서 증인이 사전에 아무런 연락 없이 감치재판기일에 출석하지 않으면 특별한 사정이 없는 한 기일을 연기할 필요 없이 심리를 진행하여 결정을 함이 타당하다. 다만 증인이 미리 법원에 증인신문기일이 지정되면 반드시 증언을 하겠다는 취지로 기일의 연기를 신청하는 경우 등에는 앞서와 같이 감치재판기일을 증인신문기일과 같은 날로 지정하여 증인에게 출석하여 증언할 수 있는 기회를 한 번 더 부여하는 운영도 고려해 봄직하다.

(2) 심리절차

감치재판기일에는 법원은 증인의 출석 없이 재판을 여는 경우를 제외하고는 증인에게 감치사유를 고지하고 변명할 기회를 주어야 하고(민소규 86조 6항, 법정질서규 6조 2항), 필요하다고 인정한 때에는 직권으로 증인 또는 참고인을 심문하거나 기타 방법으로 사실을 조사할 수 있다(민소규 86조 6항, 법정질서규 6조 3항). 감치재판을 받는 증인은 재판지연의 우려가 없는 경우에 한하여 변호사의 보조를 받을 수 있다(민소규 86조 6항, 법정질서규 7조).

증인이 감치될 경우 뒤에서 보는 바와 같이 증인과 일정한 관계에 있는 사람에게 감치재판의 집행사실을 통지하여야 하므로, 증인이 감치재판기일에 출석한 경우에는 증인으로부터 통지받을 사람의 인적사항과 연락처를 확인하여 조서에 기재하여 두는 것이 바람직하다.

(3) 기일조서의 작성

참여사무관은 감치재판기일에 참여하여 다음 사항을 기재한 조서를 작성하고, 재판장과 참여사무관이 이에 기명날인하여야 한다(민소규 86조 6항, 법

정질서규 8조).

- ① 사건의 표시
 - ② 재판기일의 일시와 장소
 - ③ 법관, 참여사무관의 관직, 성명
 - ④ 증인, 보조인의 성명
 - ⑤ 증인의 출석 여부 및 궐석으로 재판하는 때에는 그 사유
 - ⑥ 감치사유의 요지
 - ⑦ 증인에게 변명할 기회를 준 사실과 그 진술한 사실의 요지
 - ⑧ 사실조사에 관한 사항
 - ⑨ 재판의 선고일시
 - ⑩ 출석한 증인에게 불복할 기간과 불복할 법원을 알려준 사실
- (4) 불처벌결정

증인에게 증인신문기일에 출석하지 않은 데 정당한 사유가 있는지 여부를 심리한 결과 불출석에 정당한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 불처벌결정을 하여야 한다.

감치재판절차를 개시한 후 감치결정 전에 그 증인이 증언을 한 경우에도 불처벌결정을 하여야 한다(민소규 86조 3항 전단). 증인감치는 불출석에 대한 제재의 성격을 가지는 것이기는 하지만 궁극적으로는 증인의 증언을 간접적으로 강제하는 수단으로서, 행위에 대한 제재만을 의미하는 형사처벌과는 그 성질을 달리하기 때문이다.

감치의 사유가 인정되지만 감치에 처하는 것이 상당하지 아니하다고 인정되는 때에도 불처벌결정(전산양식 A2512)을 하여야 한다(민소규 86조 3항 후단). 이는 감치의 사유는 있지만 감치의 필요성이 없다고 인정되는 경우(대체 증인이나 다른 증거방법이 제출되어 증인에 대한 출석증언을 강제할 필요가 없게 된 경우, 본안소송이 화해·조정 등으로 종결되어 증언의 필요성이 없게 된 경우 등), 증인을 감치에 처하는 것이 가혹하다고 인정할 만한 특별한 사정이 밝

혀진 경우(증인이 고령, 질병 등의 사정이 있는 경우) 등을 의미한다.

불처벌결정에 대해서는 불복할 수 없다(민소규 86조 4항). 증인은 당연히 불처벌결정에 대하여 불복할 이익이 없으며, 증인 감치재판은 법원의 직권으로 개시되는 절차로서 본안소송의 당사자가 불처벌결정에 대하여 불복을 하게 허용하는 것도 타당하지 않기 때문이다.

(5) 감치결정

법원은 감치재판기일에 증인이 불출석한 데 대하여 정당한 사유가 있는지 여부를 심리한 후 정당한 사유가 없다고 인정되고 또한 불처벌결정을 하여야 할 경우가 아니라면 증인을 7일 이내의 감치에 처하는 감치결정(전산양식 A2511)을 하게 된다(민소 311조 2항). 법원이 감치결정을 할 때에는 감치할 장소를 지정하여야 하며, 이미 구금된 사람이면 그 구금시설을 감치장소로 지정한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 7조의2).

감치결정은 가능한 한 감치사유의 심리를 종료한 후 결정의 선고를 위한 별도 기일을 지정함이 없이 그 기일에 바로 선고하는 것이 집행절차나 업무 부담 면에서 바람직하다. 따라서 특히 증인이 감치재판기일에 출석하여 감치결정을 하는 경우에는 그 집행에 따른 준비를 미리 하여 둘 필요가 있다. 또한 감치재판기일에 증인이 출석하여 당일 집행이 된 경우는 물론 불출석 상태에서 감치결정을 한 경우에도 그 후 증인이 감치되면 바로 증인신문기일을 열어야 하므로, 감치결정을 할 때는 본안사건 당사자의 연락처 등을 사전에 확인하는 등으로 증인신문에 대한 준비에도 철저를 기할 필요가 있다.

감치결정은 법정에서 선고함으로써 그 효력이 발생한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 10조 1항 전문). 감치재판기일에 증인이 출석하였는지 여부는 감치결정의 효력 발생에 영향이 없다.

감치결정을 선고하는 때에는 감치사유의 요지와 적용법조를 명시하여야 하고 증인이 출석한 경우에는 불복할 기간과 불복할 법원을 알려 주어야 한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 10조 1항 후문).

증인이 출석하지 아니한 상태에서 감치재판을 선고한 때에는 지체 없이 재판서 또는 재판의 내용을 기재한 조서의 등본을 증인에게 송달하여야 한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 10조 2항). 재판의 효력은 법정에서의 선고에 의하여 이미 발생하였지만 불출석한 증인에게 불복의 기회를 부여하기 위해서이다.

감치결정을 한 법관은 그 재판서를 작성하고 서명날인하여야 한다. 재판서에는 증인의 성명·주거 기타 증인 본인을 특정하는 데 필요한 사항과 결정의 주문 및 감치사유의 요지와 적용법조를 기재하여야 하고(민소규 86조 6항, 법정질서규 11조 1항), 재판의 내용을 조서에 기재하게 하여 재판서의 작성을 갈음할 수 있다(민소규 86조 6항, 법정질서규 11조 2항).

5. 기록의 조제

감치재판개시결정이 되면 참여사무관은 지체 없이 감치·과태료재판사건으로 전산입력하고, 별책으로 기록을 만들어야 한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 25조 1항, 2항). 사건부호는 증인감치사건에 해당하는 ‘정가’를 붙이고(사전부호예규 [별표]), 사건명은 ‘증인감치’로 함이 적당하다. 그리고 사건기록표지는 [전산양식 A1093]을 사용하고, 본안사건의 사건번호를 관련사건으로 기재하고(재일 2003-11 기록표지의 관련사건 표시 및 비닐커버 사용 등에 관한 업무처리요령), 본안사건의 내용을 파악할 수 있는 최소한의 자료, 과태료재판 이후 증인에 대한 출석요구절차와 불출석의 사실을 증명할 수 있는 자료를 등분하여 첨부하며, 감치재판절차 개시 후에 작성·접수된 서류 일체를 편철하여 조제한다.

구체적으로는, 본안기록표지, 증인등목록, 소장, 증인신청서, 해당 증인의 채택 사실이 표시된 변론조서, 과태료결정서, 과태료재판 후 다시 지정된 기일의 출석요구절차를 위한 여비예납서, 출석요구서의 송달현황목록, 해당 증인이 불출석한 사실이 표시된 변론조서 등의 등본을 편철하면 될 것이다. 등

본을 할 문서의 범위에 관하여 의문이 있을 때에는 참여사무관등은 재판장과 협의하여 그 범위를 특정하여야 한다.

감치사건의 기록은 본안사건 기록과 침철함이 타당하다. 과태료 사건 문건은 원칙적으로 본안사건 기록에 가철하는 것과 대비된다.

6. 감치결정에 대한 즉시항고

가. 즉시항고권자

증인은 감치에 처하는 결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있다(민소 311조 8항). 검사나 본안사건의 당사자는 과태료 사건과 마찬가지로 당사자가 아니기 때문에 즉시항고권이 없다. 이 경우의 즉시항고에는 일반적인 즉시항고(447조)와 달리 재판의 집행을 정지시키는 효력이 없다(311조 8항 단서).

나. 즉시항고기간

즉시항고기간은 감치결정을 고지받은 날부터 1주이다(민소 444조 1항). 증인이 경찰서 유치장·교도소 또는 구치소 등 시설에 구금 또는 감치되어 있는 경우 즉시항고의 제기기간 내에 항고장을 그 시설의 장 또는 그 직무를 대리하는 자에게 제출한 때에는 그 제기기간 내에 즉시항고를 한 것으로 본다(민소규 86조 6항, 법정질서규 18조).

감치결정은 선고에 의하여 바로 효력이 발생하지만 이에 대한 불복기간은 감치결정이 증인에게 실제로 고지된 날부터 기산한다. 따라서 증인이 감치결정의 선고 시에 출석하였다면 그 선고일부터 1주 이내에, 선고 시에 불출석하였다면 감치결정 등본을 송달받은 날부터 1주 이내에 즉시항고를 하면 될 것이다. 증인이 자기가 책임질 수 없는 사유로 적법한 제기기간 내에 즉시항고를 하지 못한 때에는 재판법원에 즉시항고권의 회복청구를 할 수 있고, 그 회복청구는 사유가 종료한 날부터 1주 이내에 즉시항고와 함께 하여야 한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 19조).

다. 원심법원의 처리

증인이 감치결정에 대하여 즉시항고를 제기한 경우, 원심법원은 즉시항고가 이유 있다고 인정한 때에는 결정으로 감치결정을 취소하고 다시 재판하여야 하며, 그렇지 않을 때에는 즉시 사건기록을 항고법원에 송부하여야 한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 13조). 기록을 송부할 때 의견서를 첨부할 필요는 없다(민소규 86조 6항).

라. 항고법원의 처리

항고심에서의 처리는 다른 항고사건의 경우와 다를 바 없다. 다만 사건부호는 증인·채무자감치항고사건의 '정라'를 붙이고(사건부호예규 별표), 사건명은 원심과 마찬가지로 '증인감치'로 붙이는 것이 적당하다. 사건기록표지는 [전산양식 A1094]를 사용한다.

항고인은 변호사를 변호인으로 선임할 수 있다(민소규 86조 6항, 법정질서규 17조).

항고법원은 즉시항고의 절차가 민사소송법과 민사소송규칙에 위배된 때 또는 즉시항고에 정당한 이유가 없는 때에는 결정으로 즉시항고를 기각하여야 하고, 즉시항고에 정당한 이유가 있는 때에는 결정으로 원심의 감치결정을 취소하고 다시 재판하여야 한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 15조).

원재판을 취소하고 다시 재판하는 경우에는 불이익변경금지의 원칙이 적용되므로 원재판보다 중한 재판을 하지 못한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 15조의2).

항고법원의 재판은 송달 또는 그 밖에 알맞다고 인정되는 방법에 의하여 고지함으로써 그 효력이 발생한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 16조).

7. 감치결정의 집행

가. 증인의 감치시설유치 및 집행절차

감치결정은 그 재판을 한 법원의 재판장의 명령에 따라 법원공무원 또는 경찰공무원이 경찰서유치장·교도소 또는 구치소에 유치함으로써 집행한다(민소 311조 4항). 항고법원이 원재판을 취소하고 다시 감치에 처하는 재판을 한 경우에도 같다(민소규 86조 6항, 법정질서규 21조 1항).

재판장의 집행명령은 감치시설의 장에게 감치결정을 받은 증인을 감치시설에 유치시키도록 명하는 것으로서 감치결정의 재판서 또는 재판의 내용을 기재한 조서의 등본이나 초본을 첨부한 서면(집행명령[전산양식 A2513])으로 한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 21조 2항).

감치결정은 그 선고일부터 3개월이 경과된 후에는 이를 집행할 수 없으므로(민소규 86조 6항, 법정질서규 21조 5항), 감치결정을 한 때에는 원칙적으로 즉시항고의 제기 여부와 관계없이 즉시 집행명령을 하는 것이 타당하다.

감치결정을 집행할 당시 증인이 다른 사건으로 구속되어 있거나 형의 집행 중에 있어 신병이 확보되어 있는 경우에는 그 구금시설의 장에게 재판장의 집행명령서를 교부하면 되므로 집행에 별다른 어려움이 없다.

감치결정을 집행할 당시 증인이 위와 같이 구금되어 있지 아니한 경우(감치결정을 받는 증인의 대부분이 여기에 해당될 것이다)에는 집행명령서만으로 증인을 감치시설로 인치할 강제력을 행사할 수 없다.

이러한 경우 법원은 집행장[전산양식 A2514]을 발부하여 증인을 구인하게 하여야 한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 21조 3항). 따라서 감치재판기일에 증인이 출석한 경우에도 증인을 바로 구인하게 하려면 집행명령서 외에 집행장을 별도로 교부하여야 한다. 증인을 구인할 장소는 특별한 사정이 없는 한 감치시설로 정함이 타당하다. 집행장은 법원공무원 또는 경찰공무원으로 하여금 집행하게 하여야 하고 교도관에게는 그 집행을 명할 수 없음에도 주의하여야 한다(민소 311조 4항 참조).

집행장에는 증인의 성명·주거 기타 증인의 본인 특정에 필요한 사항과 구인할 장소, 집행장의 유효기간, 감치의 기간, 기타 감치의 집행에 필요한 사항을 기재하고, 재판장이 서명날인하여야 한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 21조 4항). 집행장의 유효기간이 감치결정의 집행기간인 선고일부터 3개월의 기간을 넘지 않도록 유의하여야 한다.

집행장과 집행명령서를 교부받은 법원공무원 또는 경찰공무원은 감치결정을 받은 증인을 감치시설에 구인하고 감치시설의 장에게 재판장의 집행명령서를 교부하여야 한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 23조 1항). 감치시설의 장은 감치결정을 받은 증인을 유치한 때에는 수용통보서에 의하여 지체 없이 법원에 그 사실을 통보하여야 한다(민소 311조 5항, 민소규 86조 6항, 법정질서규 23조 7항).

감치의 기간은 감치에 처하는 재판의 선고일부터 기산하되, 재판의 선고 후에도 구금되지 아니한 일수는 산입하지 아니한다. 감치의 기간에 관해서는 초일은 1일로 계산하고, 항고법원이 원재판을 취소하고 다시 감치에 처하는 재판을 한 경우에 이를 집행함에 있어서는 그 감치기간에 원재판의 집행에 의하여 구금된 기간을 산입한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 22조 1항 내지 3항).

증인을 감치시설에 유치함에 있어서는 행형법 중 미결수용자에 대한 수용 절차에 의한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 23조 9항). 감치시설의 장은 감치 재판의 집행을 종료한 때에는 석방통보서에 의하여 지체 없이 법원에 그 사실을 통보하여야 한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 23조 7항).

나. 집행통보에 따른 법원의 통지

재판장은 감치시설의 장으로부터 증인이 감치시설에 유치된 사실을 통보 받으면 집행일부터 3일 안에 증인의 법정대리인·배우자·직계친족·형제자매 중 그가 지정하는 자에게 감치집행의 일시·장소, 감치결정의 이유와 보

조인 또는 변호인을 선임할 수 있다는 취지를 서면(감치집행통지서[전산양식 A2515])으로 통지하여야 한다(민소규 86조 6항, 법정질서규 23조 8항).

다만 현실적으로 3일 안에 서면으로 통지하는 것이 용이하지 않고, 또한 그것이 가능하다 하더라도 감치의 기간이 7일 이내인 점을 고려하면 가능한 신속히 증인의 가족 등에게 감치사실을 통지할 필요가 있다. 따라서 담당 재판부의 법원사무관등은 미리 감치재판의 과정에서 또는 늦어도 위 통보를 받은 후 지체 없이 감치시설의 관계자와 연락을 취하여 증인이 통지를 원하는 사람의 인적사항과 연락처(전화번호 등)를 확인하여 둘 필요가 있다.

다. 감치집행의 정지

감치결정을 받은 증인이 그 집행에 의하여 현저히 건강을 해할 우려가 있거나 기타 합당한 사유가 있는 때에는 법원은 직권 또는 증인의 신청에 의하여 결정으로 주거제한 기타 적당한 조건을 붙여 그 집행을 정지할 수 있다(민소규 86조 6항, 법정질서규 21조 6항).

감치결정에 대한 즉시항고에는 집행정지의 효력이 없기 때문에, 즉시항고를 한 경우라도 감치집행을 정지하기 위하여는 별도의 집행정지 재판을 받는 수밖에 없다.

8. 감치결정의 취소

가. 증인신문의 시행

감치시설의 장으로부터 증인을 유치하였다는 통보를 받으면 법원은 바로 증인신문기일을 열어야 한다(민소 311조 6항). 위 수용통보를 받을 때에는 종전의 증인신문기일에 맞추어 증인신문을 위한 준비(증인진술서나 증인신문사항의 제출, 반대신문사항의 준비 등)는 마쳐져 있을 것이므로 바로 증인신문기일을 열기 위해서는 신속한 기일지정과 통지가 남은 과제이다.

특히 7일 이내인 감치기간을 생각할 때 어떻게 하면 신속하게 증인으로

하여금 증언할 수 있는 기회를 부여할 것인가가 문제인데, 통상적인 기일통지서의 송달에 의한 통지는 그 소요시간을 감안하면 활용하기 어렵다. 실무상 전자송달이 다수이고 우편송달보다 신속하게 이뤄질 가능성이 있긴 하겠으나, 그보다는 전화나 팩시밀리 등을 통한 신속한 방법(민소 167조 2항)으로 기일통지를 할 수밖에 없다. 이를 위해서는 법원이 미리 당사자나 대리인(특히 변호사가 아닌 소송대리인)의 연락처(전화번호·팩시밀리번호)를 확보하여 감치집행과 동시에 기일지정과 통지가 신속히 이루어질 수 있도록 준비하여야 한다.

나. 감치결정의 취소 및 석방명령

감치재판을 받은 증인이 감치재판 집행 중에 증언을 한 때에는 법원은 바로 감치결정을 취소하고 그 증인을 석방하도록 명하여야 한다(민소 311조 7항). 감치제도가 증인의 증언을 간접적으로 강제하는 데 주된 목적을 두고 있는 제도인데 그 목적이 달성된 만큼 더 이상 증인을 구금할 필요가 없기 때문이다.

그 고지방법으로서 재판장은 증인이 증언을 마치는 즉시 법정에서 구두로 감치결정의 취소와 석방을 명하여 그 사실을 조서에 기재하거나 또는 별도의 결정서(감치취소결정[전산양식 A2516])를 미리 작성하여 두었다가 법정에서 고지하는 것도 좋을 것이다.

증인이 석방되면 재판장은 감치시설의 장에게 그 취지를 통지서[전산양식 A2517]로 통보하여야 한다(민소규 86조 5항).

불처벌결정에 대하여는 불복을 허용하지 않고 있으므로, 감치결정 취소결정에 대해서도 불복할 수 없다고 해석된다(민소규 86조 4항 유추).